



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

1	שמאי מרדכי,	תובעים
2	שמאי אופירה,	
	באמצעות ב"כ: עו"ד שי זקן	
	הרב עוזיאל 96, ירושלים	
נגד		
1	דהן חיים,	נתבעים
	באמצעות ב"כ: עו"ד איל ויטנברג	
	דהן נעמי יוכבד מרים,	
	באמצעות ב"כ: עו"ד איל ויטנברג	
2	עמר ניסים,	
	הרב עוזיאל 79, ירושלים	
	עמר אסתר,	
	הרב עוזיאל 79, ירושלים	
3	בן חמו משה	
	באמצעות ב"כ: עו"ד בן צבי קובי	
4	בן חמו דבורה,	
	באמצעות ב"כ: עו"ד בן צבי קובי	
5	קיטנר ורדה,	
	באמצעות ב"כ: עו"ד בן צבי קובי	
1	בן חמו משה	תובעים שכנגד
2	בן חמו דבורה,	בתיק: 1/419/2018
3	קיטנר ורדה	
	באמצעות ב"כ: עו"ד בן צבי קובי	
נגד		
1	שמאי מרדכי	נתבעים שכנגד
2	שמאי אופירה	



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באמצעות ב"כ: עו"ד שי זקן

תובעים שכנגד	בתיק: 1/29/2019	1	דהן חיים
		2	דהן נעמי יוכבד מרים באמצעות ב"כ: עו"ד איל ויטנברג
נגד			
נתבעים שכנגד		1	שמאי מרדכי,
		2	שמאי אופירה, באמצעות ב"כ: עו"ד שי זקן
תובעים	בתיק: 1/47/2019	1	דניאל רנה בערוש
		2	רחל אביטבול בערוש
		3	מוריס ברנרד בוף
		4	מריטין לינדה בוף באמצעות ב"כ: עו"ד דוד ברויאר יפו 33, ירושלים
נגד			
נתבעים		1	חיים דהן הרב עוזיאל 79, ירושלים
		2	נעמי יוכבד דהן הרב עוזיאל 79, ירושלים
		3	נסים עמר באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב בן צבי
		4	אסתר עמר באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב בן צבי
		5	משה בן חמו באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב בן צבי
		6	דבורה בן חמו באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב בן צבי בן יהודה 1, ירושלים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7 מאיר קיטנר
באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב בן צבי

8 ורדה קיטנר
באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב בן צבי

פסק דין

עניינו העיקרי של פסק דין זה הוא ביצוע תשלומי איזון בגין הרחבות בניה שבוצעו במספר דירות בבית המשותף שברחוב עוזיאל 79 בירושלים, הידוע כגוש 30166 חלקה 368 (להלן – הבית המשותף), ובכלל זאת מהו המועד הקובע לעניין החלטה על הרחבת בנייה, ומהו סוג התשלומים שניתן לקזז כנגד תשלומי איזון כאמור.

1. במסגרת ההליך אוחדו ארבע תביעות (בכללן שתי תביעות שכנגד) בנוגע לבית המשותף. שתי התביעות הראשיות הן לדמי איזון ושתי התביעות שכנגד מתייחסות בעיקרן לתשלומים שעל פי הטענה הוציאו התובעים שכנגד לצורך קידום תב"ע לתוספת זכויות בבית המשותף, והוצאות נוספות הקשורות בכך.

2. בבית המשותף 10 תתי חלקות. הצדדים הם בעלי 7 מתוך 10 דירות בבית המשותף כדלקמן:

א. התובעים שמאי, בהליך 418/18 (והנתבעים שכנגד בהליך 419/18 ובהליך 29/19) (להלן – התובעים שמאי) היו במועדים הרלבנטיים להליך (לשיטתם) בעלי תת חלקה 3.

ב. התובעים בוף בהליך 47/19 (להלן – התובעים בוף) הם בעלי תת חלקה 7.

ג. התובעים בערוש בהליך 47/19 (להלן – התובעים בערוש) הם בעלי תת חלקה 5.

ד. הנתבעים דהן בהליך 418/18 ובהליך 47/19 (והנתבעים שכנגד בהליך 29/19) (להלן – הנתבעים דהן) הם בעלי תת חלקה 1.

ה. הנתבעים עמר בהליך 418/18 ובהליך 47/19 (להלן – הנתבעים עמר) הם בעלי תת חלקה 8.

ו. הנתבעים בן חמו בהליך 418/18 ובהליך 47/19 (והנתבעים שכנגד בתיק 419/18) (להלן – הנתבעים בן חמו) הם בעלי תת חלקה 9.

ז. הנתבעים קיטנר בהליך 418/18 ובהליך 47/19 (והנתבעים שכנגד בתיק 419/18) (להלן – הנתבעים קיטנר) הם בעלי תת חלקה 10.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. הנתבעים דהן, עמר, בן חמו וקיטנר קידמו תב"ע שמספרה 13716 לצורך תוספת זכויות בניה לבית המשותף, התב"ע אושרה ביום 11.7.2012 (להלן – התב"ע). כפי שיורחב בהמשך, התב"ע אפשרה תוספת זכויות נרחבות לדירות הנתבעים, ותוספת זכויות פחותה בהרבה לדירות התובעים. בפועל, הנתבעים הרחיבו את דירותיהם על פי היתרי בניה שניתנו להם, על בסיס זכויות שנוספו במסגרת התב"ע. התובעים בשתי התביעות, שמאי בהליך 418/18 ובוף ובערוש בהליך 47/19 הגישו תביעות נגד כל הנתבעים בדרישה לתשלומי איזון בגין אותן הרחבות.

4. באשר לתביעה העיקרית שהגישו התובעים שמאי כלפי כל הנתבעים לדמי איזון:

הנתבעים בן חמו וקיטנר הגישו תביעה שכנגד כלפי התובעים שמאי בהליך 419/18 בדרישה לביצוע תשלומים בגין התב"ע שקודמה על ידם (עם הנתבעים האחרים) ואשר הביאה לתוספת זכויות גם לדירת התובעים שמאי.

הנתבעים דהן הגישו גם הם כלפי התובעים שמאי תביעה שכנגד בהליך 29/19 בגין השבת החלק היחסי שהוציאו הנתבעים דהן לצורך הליכי תכנון ופיתוח בנוגע לאותה תב"ע, ובדרישה לפיצוי בגין פגיעה בפרטיות.

5. באשר לתביעה העיקרית שהגישו התובעים בוף ובערוש כלפי כל הנתבעים, לא הוגשו תביעות שכנגד, אך קיימת חפיפה בטענות הנתבעים בשני ההליכים העיקריים באשר לזכות לקזז הוצאות שהוציאו לצורך תוספת הזכויות במסגרת התב"ע, וכן טענות נוספות המתייחסות באופן ייחודי לתובעים השונים.

טענות הצדדים בקצרה

6. לטענת התובעים שמאי בתיק 418/18 (ובתביעה שכנגד בתיק 419/18 ובתיק 29/19) - על פי היתר הבניה שניתן לנתבעים אושרו לנתבעים תוספות בניה בהיקף נרחב העולה באופן משמעותי על חלקם היחסי ברכוש המשותף. לטענתם ההחלטה לעניין ביצוע ההרחבות נתנה ביום 26.12.2016 עם הסכמתו של הדייר ירקוני, דבר שנועד לתובעים במועד מאוחר יותר, ועל כן תביעתם הוגשה במועד, דבר שאף הוכרע בעבר.

7. לטענתם ההרחבה שהם ביצעו בדירתם אינה מהווה הרחבה דומה לזו שביצעו הנתבעים.

8. עוד לטענתם, על פי חוות הדעת של השמאית שמונתה מטעמי, עולה כי תשלומי האיזון המגיעים להם מהנתבעים הם בסך של 380,168 ₪ על פי תחשיב של השמאית מטעמי לשנת 2021, דבר שאף תואם את תחשיב השמאי מטעמם.

9. לטענתם, הנתבעים פיצלו דירותיהם בניגוד לחוק, ועל כן נדרשת הסכמה של 100% מבעלי הדירות. עובדה זו מייתרת את הצורך לבחון את מועד ידיעתם אודות הסכמת הדייר ירקוני להרחבה, שכן ממילא באותו מועד לא היו קיימות ההסכמות הנדרשות של כלל בעלי הדירות.

10. לטענתם אין מקום להפחית מדמי האיזון את הוצאות התכנון עבור קידום תב"ע 13716 משום שהנתבעים קידמו את התב"ע על דעת עצמם ללא שיתוף התובעים. לטענתם,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השמאית הפחיתה סכומים גבוהים מהנדרש בגין הוצאות תכנון, שכן בחקירות הנגדיות של הנתבעים עלה שהסכומים שמסרו לשמאית אינם מבוססים. טענת הנתבעים לעניין שכר ראוי בגין יזום נזנחה על ידם אך גם אין לה כל אסמכתה או בסיס משפטי. באשר להוצאות לשיפוץ הגג, היה על הנתבעים להביא את ההחלטה בעניין לאסיפה הכללית, אולם הדבר לא נעשה.

11. לטענת התובעים, יש לדחות את טענת הנתבע דהן באשר להסכמה בדבר תשלום של \$6,000 כתמורה לזכויות הבניה אשר לא הוכחה. לטענת, לא קיים היקף ההסכמות הנדרש להצמדת השטח הבלתי מנוצל והגינה לדירת דהן.

12. כן יש לדחות את טענת דהן לעניין פגיעה בפרטיותו אשר לא הוכחה.

13. לטענת הנתבעים דהן בתיק 418/18 (ובתביעה שכנגד בתיק 29/19) – חוות דעת שמאית בנוגע לשטחים שנוצלו על ידם נתנה עוד בשנת 2004 בהזמנת נציגות הבית המשותף. דהן פנו לדין תורה בעניין כנגד הנציגות ושילמו למספר דיירים את הסכום שהוסכם. העבודות להרחבת הדירה בוצעו על ידי דהן עוד בשנת 2007.

14. לאור העברת ההליך מתביעה ובתביעה שכנגד מבית משפט השלום ללשכת המפקחת, קנתה המפקחת סמכות לדון גם בתביעה שכנגד.

15. החצר והחלל בהם בנו דהן היו ללא שימוש במשך עשרות שנים ולא הייתה גישה סבירה אליהם, וחברי הנציגות דאז אישרו לדהן להשתמש ולבנות בהם. בהמשך לכך התקיימה אסיפה כללית אשר התובעים שמאי השתתפו בה ובעקבות כך ב-2004 הוצאה חוות דעת שמאית לבקשת הדיירים, ובראשם נציג הוועד שהיה מתואם עם התובעים שמאי. דהן הסכימו לשלם את הנדרש על פי חוות הדעת אולם נציג הוועד ושמאי סירבו לקיים את ההסכמה. בעלי הדירות ובהם שמאי החליטו להציע את השטח לקבלן, ועל כן דהן תבעו אותם לדין תורה. בית הדין פסק שלאחר שיושג הסכם עם הקבלן יהיה דיון בו דהן יוכלו להתמחר עם הקבלן. לאחר שסוכם מחיר עם הקבלן, הסכימו דהן להשוות את התמורה ולשלם \$6,000 לכל דירה עבור ויתור על הזכויות בה. בכך נכרת הסכם. ב-2006 נחתם ההסכם בין דהן לבערוש ובהמשך עם כהן. ב-2016 נחתם הסכם עם ירקוני. בעלי דירות אחרים ביקשו סכומים גבוהים מ\$6,000 ועל כן לא חתמו על הסכם.

16. גם אם יש מקום לביצוע תשלומי איזון לתובעים שמאי – על פי חלקם היחסי 20.8% שהם 102,521 ₪, אין קשר בין דמי האיזון לחצר, שכן דהן לא ביצעו בניה בחצר. בהפחתת שטחי החצר מחוות הדעת, הסכום לו זכאים שמאי הוא 59,881 ₪. כמו כן יש להפחית את הסכום ששולם על ידי דהן להחלפת קווי הביוב בבניין בסך של 100,000 ₪. לאחר הפחתת סכום כאמור החלק של שמאי הוא 41,034 ₪.

17. המועד הקובע צריך להיות 2012, מועד אישור התכנית.

18. שמאי הגישו את התביעה בשיהוי ניכר, והתביעה התיישנה.

19. ההחלטה להצמדת שטחי החלל והחצר התקבלה בשנת 2004 ולאחר מכן בשנת 2006.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. באשר לתביעה שכנגד, השמאי פטל נכנס לדירת הנתבעים דהן במרמה והחל לצלם בה. לפיכך על פי חוק הגנת הפרטיות רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע בפיצוי עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק. האירוע האמור פגע בנפש בנותיהם של התובעים שכנגד, ועל כן מתבקש לחייב את התובעים שמאי בסך של 50,000 ₪.

21. לטענת הנתבעים קינטר, בן חמו, עמר בתיק 418/18 (ובתביעה שכנגד בתיק 419/18) – יזמו וקיידמו מאז 2008 תכנית להרחבות בכל יחידות הבית המשותף, וקיבלו הסכמות של הרוב הדרוש הן לתוכנית והן להיתר הבניה. לדירת התובעים שמאי אושרה הרחבה במסגרת התב"ע בהיקף של 26 מ"ר אף שסירבו להשתתף בעלויות.

22. התב"ע משייכת את זכויות הבניה לנתבעים באופן פרטני בדומה להקצאה קניינית ואינה משייכת אותן לכלל בעלי הדירות. בנספח הבינוי של התב"ע הוגדרו מראש מיקום והיקף זכויות הבניה לכל דירה.

23. בין התובעים שמאי לנתבעים קינטר עמר ובן חמו הושג בשנת 2016 סיכום לעניין גובה תשלומי האיזון תוך לחיצת ידיים, ולאחר מכן שמאי חזר בו מהסיכום באמצעות בנו, ודרש להעלים את התשלומים מרשויות המס.

24. שמאי לא הציג עדות מהימנה, וטען מספר פעמים שאינו זוכר.

25. לתובעים שמאי אין זכות עמידה כבעל דירה שכן ידיעת שמאי על הבניה בפועל הייתה לאחר שמכרו את זכויותיהם. מסמך המחאת הזכויות מהרוכשים נעשה רק בדיעבד לאחר שימוש בזכויות הבניה ואינו תקף לעניין תובענה מסוג זה.

26. התביעה התיישנה, שכן המו"מ בין שמאי לנתבעים פסק לכל המאוחר באוגוסט 2016 ומאז עברו למעלה מ-30 יום עד להגשת התביעה. בנוסף, הוכח שהבניה החלה באוגוסט 2016, לפני המועד עליו נשענה ההחלטה מיום 30.3.2020 בבקשה לסילוק על הסף. התובע שמאי עצמו אישר לרוכש הרחבת דירתו מכח התב"ע כבר בדצמבר 2016. בנוסף, התובע שמאי עצמו דרש דיסקרטיות מהנתבעים לעניין ההסכמות, ועל כן מושתק מלטעון שלא קיבל מידע על הסכמת ירקוני. נוסף על כך, לתובע שמאי לא היה הסבר למועד בו הוגשה התביעה. עוד לטענת הנתבעים, התובע שמאי הזמין שומה עוד באפריל 2016 ומהנסיבות עולה שהוזמנה במסגרת המו"מ להסכמות כספיות. הרחבת דירת שמאי נעשתה על חשבון זכויות ירקוני ועל כן לא יתכן שלא ידע על הסכמת ירקוני להרחבות שביצעו הנתבעים. מכל מקום, היה עליו לזמן את ירקוני כדי להוכיח זאת.

27. המועד הקובע הוא שנת 2012, והתובע שמאי הוא שחייב בביצוע תשלומי איזון. יש להפחית מחוות הדעת היטל מדרגות מפלס עליון, להפחית עלויות הכשרת הגג הישן, ולהפחית עלויות הקמת המעלית.

28. יש להפחית את הוצאות ששולמו על ידם בגין תכנון התב"ע, העולות על 37,000 ₪.

29. הנתבעים עומדים על השומה מטעמים שכן לטענתם משאלות ההבהרה שהועברו לשמאית מטעם המפקחת עולה כי לא ניתן להפיק משומתם סכום מתוכלל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. יש לקבל את התביעה שכנגד, אשר לטענת הנתבעים הוכחה על ידם, ותצהיריהם בעניין לא נסתרו.

31. לטענת התובעים בוף ובערוש בתיק 47/19 – תב"ע מספר 13716 שאושרה ביום 11.7.2012 מאפשרת את הגדלת דירות הנתבעים בשיעור העולה על חלקם היחסי ברכוש המשותף. היתר מספר 109973 מיום 20.6.2016 אף הוא מאפשר הרחבה כאמור.

32. עם הגשת התביעה הסכימו התובעים להגדלת דירות הנתבעים. ככל שאפשר להרחיב את דירת התובעים, הרי שניתן לעשות זאת באופן קטן בהרבה מחלקם ברכוש המשותף.

33. התביעה לא הוגשה לאחר המועד הקבוע בחוק שכן לא התקיימה אסיפה כללית לעניין ההרחבות נשוא ההליך וכן כפי שהובהר בהחלטה שנתנה בעבר, יש למנות את המועד מהיום בו הומצאה הסכמה כתובה של משפחת ירקוני לידי התובעים. הוכח כי לא הומצאה לתובעים הסכמה כאמור. הנתבעים ויתרו על זימון ירקוני לעדות ועל כן חזקה שהעדות הייתה פועלת לרעתם.

34. לתובעים לא הומצאו הסכמות של אף אחד מבעלי הדירות בבית המשותף. גם אם הייתה מוצגת הסכמת ירקוני, לא היה לנתבעים את הרוב הדרוש לביצוע ההרחבות לאור התנגדות התובעים דן והתנגדות התובעים שמאי.

35. כפי שנקבע בפסיקה, הסכמה כאמור צריכה להיות ברורה ומפורשת.

36. גם אם לא יתקבלו הטענות, נסיבות העניין מצדיקות הארכת מועד להגשת תביעה בעניין. הנתבעים הם שהפרו את הוראות הדין בכך שלא שילמו דמי איזון במועד הקבוע בחוק.

37. אין בסיס לטענת השתק ומניעות כלפי בערוש. בין בערוש לנתבעים היו הסכמות מותנות, אך הנתבעים לא קיימו את התנאים שהוסכמו. הנתבעים לא הוכיחו שקיימו את חלקם בהסכמות. משלא בוצעו ההסכמות במועד שנקבע, הן בטלות.

38. אין בסיס לטענה שבערוש מכרו לנתבעים דהן חלל הכולל זכויות בניה וכן חצר בשנת 2006. בערוש מכרו חלל בלבד, וזכויות הבניה נוצרו רק 6 שנים לאחר מכן. הטענה למכירת חצר עומדת בניגוד ללשון ההסכם.

39. הטענה שהובטחו לנתבעים דהן שטחים מהרכוש המשותף לשימוש ייחודי אינה נכונה ולא הוכחה. בכל מקרה גם אם הייתה הבטחה כאמור על ידי נציגות הבית המשותף היא אינה יכולה לחייב את בעלי הדירות.

40. הטענה לפסק בורר לעניין דמי איזון בסך של \$6,000 לכל דייר אין בה ממש והנתבעים כלל לא חתמו על שטר בוררות בעניין, וכן פסק הבורר שצורף אינו קובע את מה שנטען. בנוסף, במועד בו ניתן, התב"ע כלל לא הייתה בתוקף, ועל כן הזכויות בגין נדרשים דמי האיזון כלל לא היו קיימות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. המועד הקובע לתשלום דמי האיזון הוא מועד מתן חוות דעתה של השמאית מטעם המפקחת. וככל שייקבע מועד מוקדם יותר, יש להטיל הפרשי הצמדה וריבית מהמועד הקובע ועד לביצוע התשלום בפועל.

42. קיזוז היטלי השבחה מדמי האיזון צריך להיות מהסכומים ששולמו בפועל ולא על פי תחשיב רעיוני. נטל הוכחת טענת הקיזוז מוטל על מי שטוען לה.

43. על הנתבעים הנטל להוכיח מהן עלויות התכנון שנשאו בהן ושלטענתם יש לקזזן מתשלומי האיזון. על פי הראיות שצרפו הנתבעים מדובר בסך כולל של 37,228 ₪ וגם לגביו לא הוכח שאכן שולם לטובת התכנון.

44. לטענת הנתבעים דהן בתיק 47/19 – התובעים בערוש ויתרו על הזכויות בחלל עוד בשנת 2006 ואף חתמו על הסכם בעניין וקיבלו תמורה כספית, בהתאם להשתלשלות העניינים כפי שפורטה לעיל לעניין תביעת שמאי.

45. התביעה התיישנה. ההסכם הושג בשנת 2006 והתביעה הוגשה 13 שנים לאחר האירועים הרלוונטיים.

46. התובעים בערוש הודו בכתב התביעה שהגישו שמכרו את זכויותיהם בחלל הנדון, ורק בהמשך ההליך ניסו לחזור בהם מהודאתם.

47. ההסכם שנחתם עם דהן התייחס גם לחלל וגם לגינה, בהתאם להסכם המכר שהיה בין הקבלן לדיירים. התנהלות בערוש לאחר ההסכם מראה שהם הבינו זאת כך, אף שבשלב מסוים חלקו על הזכות בגינה (מה שהביא לכך שלא צוין תאריך על ההסכם עמם).

48. התשלום בוצע בגין החלל והגינה וזכויות הבניה בהם שכן היה מובן שדהן מתכוונת לבנות בחלל ולהשתמש בגינה.

49. התובעים בוף אמנם לא חתמו על ההסכם, אבל הם חלק ממנו, שכן שיתפו פעולה עם הנציגות כדי להביא להסכם לעניין ויתור על הזכויות האמורות, ואחר כך שינו את דעתם. בעקבות ההליך בדין תורה גובשה ההצעה מטעם בעלי הדירות שהתקבלה על ידי דהן ועל כן מדובר במעשה עשוי.

50. לחלופין – יש להפחית מחוות דעתה של השמאית מטעם המפקחת סכומים בגין החצר ובגין החלפת קווי הביוב בבית המשותף, ולאחר ההפחתה התוצאה היא סך של 42,970 ₪ לבערוש וסך של 43,924 ₪ לבוף. המועד הקובע הוא שנת 2012, מועד אישור התכנית.

51. לעניין היטל השבחה – הפטור הוא חד פעמי ועל כן אין הצדקה להתחשב בהיטל ששולם בפועל אלא בחישוב העקרוני התיאורטי. כמו כן נגרמו הוצאות תכנון בסך בעולה על 37,000 ₪ ובהקשר זה לנתבעים נגרם נזק ראיתי.

52. לטענת הנתבעים קינטר, בן חמו, עמר בתיק 47/19 – הם יזמו וקידמו מאז 2008 תכנית להרחבת בבית המשותף. גם עבור בוף ובערוש אושרה בתב"ע הרחבה בהיקף של כ-8 מ"ר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אף שסירבו להשתתף בעלויות לקידום התב"ע. בוף ובערוש הגיעו עוד ב2016 להסכמה לעניין תשלומי איזון אולם חזרו בהם ברגע האחרון.

53. התב"ע משייכת את זכויות הבניה לנתבעים באופן פרטני בדומה להקצאה קניינית כנטען לעיל בעניין התביעה בתיק 418/18.

54. קיים השתק ומניעות. בערוש התקשר בהסכם מחייב מול הנתבעים בשנת 2016, שקבע שבתמורה להסכמת בערוש, הנתבעים מתחייבים לסייע לו לקבל הסכמה של שכן אחר (בראון) להרחבת דירת בערוש. הנתבעים קיימו התחייבותם בנושא זה. ראשית, משום שבערוש כלל לא ביררו אם השכן נתן הסכמה, אף שבנם שוחח עם השכן בעניין, ולא נתנו כל התייחסות לנושא זה, גם לא בתצהיר הבן, ונמנעו מלהעיד את השכן. התובעים מצדם קיימו פגישות עם השכן ועם בערוש כדי לסייע בעניין. בנוסף, בערוש נמנע מלהגיש בקשה להיתר בניה לצורך הרחבת דירתו ובכך סיכל בעצמו את האפשרות להרחיב את דירתו. בניגוד לטענת בערוש שאם לא יתקיים התנאי ההסכם יפקע, נקבע בהסכם שתתקיים פגישה נוספת אולם בערוש לא ביקש פגישה נוספת ומכאן שנודע לו על הסכמת השכן. בנוסף, לא הייתה כל הסכמה על השגת הסכמת השכן בכתב, ואף לא על השגת ההסכמה אלא על ניסיון להשגתה.

55. באשר לבוף, הוכח שסוכם בין נציגו לנתבעים שהנתבעים יוותרו על חלקו של בוף בעלות הפרויקט ויאפשרו לו שימוש במעלית והוא יוותר על תביעות כספיות ובכללן דמי איזון.

56. לטענתם, התביעה התיישנה, שכן הוגשה למעלה מ-30 יום מהמועד בו נודע לתובעים על החלטת ההרחבה. התובעים התחמקו ממתן תשובה לעניין עיתוי המודעות שלהם להסכמת הרוב.

57. בוף ובערוש הזמינו שומה בשנת 2016 טרם הפגישה עם הנתבעים, כך שהיו מודעים להתגבשות הסכמת הרוב הדרוש. הם גם היו מודעים להרחבות הבניה שבוצעו בפועל מכח התב"ע.

58. בוף ובערוש ניהלו מו"מ בסוגיית ההתחשבנות הכספית מול הנתבעים בשנת 2016 ובערוש חתמו על הסכם ויתור באותה שנה, תוך שדרשו בניה תוך חודשיים – דרישה זו מוכיחה שידעו על החלטת ההרחבה. גם בוף הזמינו שומה לפיצוי, ומכאן שיצאו מנקודת הנחה שקיימת הסכמה לבניה של הרוב הדרוש. כל האמור אירע סביב חתימתו של ירקוני על הסכמה מטעמו – דבר שאין לו הסבר אחר אלא שבוף ובערוש היו מודעים להסכמתו.

59. בוף ובערוש הם שחייבים בתשלום דמי איזון. המועד הקובע הוא שנת 2012, שאז אושרה התב"ע והזכויות הפכו ברות מימוש. יש להפחית מחוות הדעת היטל מדרגות מפלס עליון, להפחית עלויות הכשרת הגג הישן, ולהפחית עלויות הקמת המעלית.

60. יש לקזז את היטל ההשבחה ללא הפטור שניתן, שכן מדובר בפטור אישי וקיימים נימוקים נוספים לתמיכה בכך שאין להתחשב בו.

61. יש מקום להפחית את הוצאות תכנון התב"ע ששולמו על ידם, העולות על 37,000 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההליך

62. התביעה בהליך 418/18 והתביעות שכנגד בהליכים 419/18 ו-29/19 הוגשו תחילה לבית משפט השלום בירושלים, ובתאריך 21.11.2018 הוחלט בהסכמת הצדדים להעביר לערכאה זו מבלי שתעלה טענה לעניין שיהוי לגבי התקופה שמהגשת התובענה הפותחת (30.3.2017) ועד למועד ההחלטה. לאחר מכן הוגשה התביעה הנוספת בהליך 47/19. ההליכים כולם התנהלו תחילה בפני כב' המפקחת (דאז) י' ענתבי שרון. בתחילת שנת 2021, לאחר מינויה של כב' המפקחת ענתבי שרון לשיפוט, הועברו ההליכים לטיפול.

63. הנתבעים הגישו בשני ההליכים העיקריים (418/18 ו-47/19) בקשות לסילוק על הסף של התביעות, והבקשות נדחו בהחלטות מנומקות של כב' המפקחת ענתבי שרון מיום 29.3.2020.

64. בהחלטה מיום 3.5.2020 אוחד הדיון בתובענות.

65. ביום 15.7.2020 התקיים דיון מקדמי בהליך המאוחד, בסיומו נקבע התיק להגשת תצהירים וחוות דעת, וכן נקבע שיש מקום למינוי שמאי מטעם המפקחת לבחינת דמי האיזון הראויים ככל שקיימים, אשר ימונה לאחר הגשת חוות הדעת מעם הצדדים.

66. בתאריך 9.2.2021 מיניתי כשמאית מומחית מטעמי את השמאית רלי טרייסטמן (להלן – השמאית מטעמי).

67. בתאריכים 28.12.2021, 3.1.2022 ו-19.1.2022 התקיימו ישיבות הוכחות במהלכן נחקרו העדים מטעם הצדדים. מטעם התובעים שמאי העיד מר שמאי מרדכי, מטעם התובעים בוף ובערוש העידו מר מיכאל בערוש, מר בנימין בערוש, מר דניאל בערוש, מר יואל גרבלי (חתנו של בוף), ומר בוף, מטעם הנתבעים עמר בן חמו וקיטנר, העידו מר משה בן חמו, מר קיטנר ליאור, גב' עמר אסתר ואדריכל ספקטור יוסף, ומטעם הנתבעים דהן העיד מר חיים דהן.

68. בתאריך 14.12.2021 נתנה חוות הדעת (המעודכנת) של המומחית מטעמי (להלן – חוות דעתה של השמאית מטעמי).

69. ביום 22.12.2021 הגיעו הצדדים להסדר דיוני שקיבל תוקף של החלטה. ההסדר הדיוני כלל הסכמות שונות בנוגע למשלוח שאלות הבהרה לשמאית מטעמי ולביצוע החקירות, ובנוסף ויתרו הצדדים במסגרתו על חקירת השמאית מטעמי, מבלי שיסכימו על קביעותיה, ועל חקירת השמאים מטעם הצדדים, תוך שמירה על הזכות לטעון בסיכומיהם ביחס לסוגיות שלטעמם לא זכו להתייחסות מתאימה בחוות הדעת המתוקנת של השמאית מטעמי.

70. ביום 14.12.2021 וביום 25.1.2022 נתנה השמאית מטעמי מענה לשאלות הבהרה שנשלחו אליה מטעם הצדדים.

71. ביום 2.11.2022 הגישה השמאית מטעמי מסמך משלים לחוות הדעת לעניין דמי האיזון על פי החלופה המתחשבת בקיזוז תשלומי היטל ההשבחה ששולמו בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

מעמד התובעים שמאי לעניין הגשת התביעה

72. בעניין זה נתנה החלטה מנומקת של כב' המפקחת (דאז) י" ענתבי שרון מיום 29.3.2020, אשר קבעה כי עילת התביעה נולדה במועד בו היו התובעים שמאי בעלי הדירה, שכן יש לראות את מועד ניצול זכויות הבניה על ידי הנתבעים כמועד שבו התגבשה עילת התביעה. זאת להבדיל מהמועד הקובע לצורך בחינת מועד הגשת התביעה, שהוא המועד בו התקבלה ההסכמה האחרונה המגבשת את הרוב הדרוש של בעלי הדירות לצורך ביצוע ההרחבה. אין מחלוקת שהנתבעים ביצעו בפועל את הרחבות הבניה טרם מכירת הדירה על ידי התובעים שמאי, ועל כן, בהתבסס על הניתוח המשפטי שבהחלטה האמורה, איני מוצאת מקום לשנות מהחלטה זו, על פיה אין בכך שהתובעים שמאי מכרו את דירתם במועד בו נמכרה כדי למנוע מהם הגשת התביעה דין.

בהקשר זה טענת הנתבעים שהתובעים שמאי לא ידעו על הבניה שבוצעה אלא לאחר שמכרו את דירתם, ועל כן אין להם זכות עמידה שכן עילת התביעה לא נולדה בעת שהיו בעלי הדירה, נדחית. עילת התביעה נולדה במועד בו נצלו הנתבעים את זכויות הבניה בין אם שמאי ידעו על כך ובין אם לא. להבדיל מהמועד בו ניתן להגיש תביעה לתשלומי איזון, הקבוע בסעיף 71ג(ב), שהוא 30 יום מיום קבלת ההחלטת ההרחבה או המצאתה לבעל הדירה התובע, אין כל תלות בין מועד היווצרות עילת התביעה לתשלומי איזון לבין המועד בו נודעו לתובע העובדות שיצרו את אותה עילה. על כן עילת התביעה נולדה בעת שבוצעה הבניה בפועל, כפי שנקבע בהחלטת כב' המפקחת ענתבי שרון. כאמור, אין מחלוקת שבאותו מועד התובעים שמאי היו בעלי הדירה. אוסיף שהנתבעים מנסים לאחוז בחבל משני קצותיו, מחד לטעון שעילת התביעה כלל לא נולדה לפני מכירת דירת שמאי, ועל כן אין לשמאי זכות עמידה, ומאידך לטעון שעילת התביעה נולדה עוד באוגוסט 2016 כך שהזכות להגשת התביעה התיישנה בחלוף 30 יום מאותו מועד. החלטת כב' המפקחת (אז) ענתבי האמורה, שמצאתי מקום לאמץ מסקנותיה, כוללת מסקנות הפוכות מאלו של הנתבעים בשני ההיבטים, כפי שפורט לעיל.

73. על כך אוסיף, שאני סבורה שהתובעים שמאי נכללו בהגדרת "בעל דירה" שיכול להגיש תביעה כאמור גם לאחר דצמבר 2016, המועד בו חתמו על ההסכם למכירת דירתם, ולפחות עד המועד בו הגישו את התביעה בפועל. התובעים שמאי הגישו את התביעה הפותחת לבית משפט השלום בתאריך 30.3.2017, והצדדים הסכימו שהעברתה לערכאה זו תעשה מבלי שתעלה טענה לעניין שיהיו באשר לתקופה שמהגשת התביעה הפותחת. לתביעה הפותחת צורף נסח רישום, מיום 27.3.2017 ממנו עולה כי עובר להגשת הייתה הדירה, תת חלקה 3, בבעלות רשומה של התובעים שמאי. מכאן שבמועד הרלוונטי להגשת התביעה, היו התובעים שמאי בעלים של הדירה, תת חלקה 3 בבית המשותף, גם אם לפני מועד זה חתמו על ההסכם למכירת הדירה (שמעמדו הוא "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין" על פי סעיף 7 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969).

74. סימן 11 בפרק ו לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) עוסק בנושא הרחבת דירה ותשלומי איזון. בעלי הזכויות הרלוונטיים בהקשר זה כפי שעולה מסימן 11 האמור, הם בעלי הדירות. בכלל זאת, על פי סעיף 71ג לחוק המקרקעין, רשאי בעל דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המתנגד להרחבה להגיש תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין. מכאן שהתובעים שמאי היו בעלי הזכות הרלוונטית להגשת התביעה במועד בו הוגשה. גם אם ניתן להכיר ברוכש דירה שטרם נרשם כבעלים כבעל הזכות לתבוע תשלומי איזון על בסיס הסכם המכר, או על בסיס נסיבות מתאימות אחרות, הרי שברירת המחל הוא שבעל הדירה הרשום הוא הזכאי לתבוע זכויות כאמור, ועל כן, לא בנקל ייקבע כי בעל הדירה הרלוונטי הוא מי שחתם לאחרונה על הסכם לרכישת הדירה והבעלות טרם הועברה על שמו. העובדה שנחתם הסכם מכירה בין התובעים שמאי לרוכשי דירתם באוגוסט 2016, ואף שבסמוך לאחר מכן החלו הרוכשים בביצוע עבודות שיפוץ בדירה, אינה מספקת כדי להביא למסקנה שזכויות הבעלות הועברו בפועל משמאי לרוכשי הדירה כבר באותו מועד, וכי נושא הרישום נותר "טכני" כטענת הנתבעים. מחקירתו הנגדית של התובע שמאי עלה כי במועד שבו ביצעו הרוכשים שיפוץ בדירה, עדיין לא שולמה מלוא התמורה (דבר הנתמך גם במועדי תשלום התמורה שבהסכם המכר שנחתם ביום 11.12.2016. נספח ד לתצהיר התובע שמאי), ושמאי הסכים שישפץ את הדירה למרות שעסקה עדיין לא הושלמה (ר' פרוטוקול הדיון מיום 28.12.2021 עמוד 12 שורות 50-22).

75. יתר על כן, במקרה דנן, כפי שעלה מ"כתב המחאת זכויות" שהוצג טרם מתן ההחלטה הנ"ל (צורף כחלק מנספח ד לתצהיר התובע שמאי), רוכשי דירת התובעים שמאי חתמו על מסמך על פיו בין היתר הזכות לתביעת תשלומי איזון שמורה לתובעים שמאי. בנסיבות אלו, לא עולה כל חשש שהנתבעים יידרשו לשלם פעמיים, ואין כל הגיון לפטור אותם לחלוטין מתשלום דמי איזון בגין דירת התובעים שמאי, ככל שיימצא שהם חייבים בכך.

בהקשר זה, טענות הנתבעים לעניין היעדר אפשרות להמחות את הזכות לתבוע תשלומי איזון מתייתרות, שכן שמאי ממילא היו בעלי הזכות לתבוע תשלומים כאמור. למעלה מן הצורך, אבהיר שאני סבורה שגם אין מקום לקבל טענות אלו. ר' לעניין זה גם פסקה 13 להחלטת כב' המפקחת ענתבי שרון מיום 29.3.2020. אין המדובר בהמחאת זכויות בניה או בהמחאת זכות תביעה, אלא בכך שהתובעים שמאי שמרו על זכותם כלפי רוכשי הדירה, לקבל תשלומי איזון.

מועד החלטת ההרחבה והמועד להגשת התביעות

76. סעיפים 71ב ו-71ג **לחוק המקרקעין**, עוסקים בהיבטים הנוגעים להחלטה על הרחבת דירה, ובמועד שבו ניתן להגיש תביעה לתשלומי איזון למפקח על רישום מקרקעין:

"71ב(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ג) בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

(ז) לא נתקבל החלטת ההרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה.

71ג (א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח בתביעה.

(ב) התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, ואם בעל הדירה לא היה נוכח בעת קבלת ההחלטה, תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) הוראות סימן ד' לפרק זה יחולו על הדיון בפני המפקח, בשינויים המחוייבים.

(ד) ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לענין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין.

(ה) אין בפניה למפקח, כשלעצמה, כדי להוות עילה לעיכוב ביצוע ההרחבה, אלא אם כן הורה המפקח אחרת. " (ההדגשות אינן במקור, א.ש)

77. כפי שנקבע בהחלטות כב' המפקחת ענתבי שרון מיום 29.3.2020, אין מחלוקת שלא התקיימה אסיפה כללית במסגרתה התקבלו החלטות לאשר לנתבעים את ביצוע ההרחבות ברוב בעלי הדירות הנדרש בדיון. עם זאת, הדיון אינו מחייב קיומה של אסיפה כללית לצורך קבלת הסכמות אלו [ר' ע"א (מחוזי ירושלים) 1415/00 אברהם נ' אזרד (לא פורסם), 4.7.2001]. לפיכך, לצורך הוכחת טענת הנתבעים שחלפו יותר מ-30 יום לצורך הגשת תביעה על פי סעיף 71ג(ב) ועל כן לא ניתן להגיש תביעה, היה על הנתבעים להוכיח שהומצאו לתובעים, או לפחות הובאו לידיעתם, הסכמות רוב בעלי הדירות הנדרשות לצורך ביצוע ההרחבות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

78. בהחלטת כב' המפקחת ענתבי שרון מיום 29.3.2020, בכל הנוגע לתובעים שמאי, צוין כי לשם בחינת מועד הגשת התביעה לצורך סעיף 71ג(ב) יש לבחון את "המועד הקובע" כמועד בו התקבלה הסכמה אחרונה המגבשת קבלת רוב בעלי הדירות על פי דין (פסקה 9 להחלטה בבקשה 51/19). נמצא כי מועד זה היה ביום 29.12.2016, המועד בו הסכים ירקוני, בעל דירה אחרת, להרחבה, ככל שהסכמה זו הומצאה לתובעים שמאי, או לחלופין מועד קבלת ההסכמה האחרונה אצל התובעים שמאי. מכאן, שלגבי התובעים שמאי, יש למנות את 30 הימים הקבועים בסעיף 71ג(ב) החל מאותו מועד.

79. באשר לתובעים בוף ובערוש נקבע בהחלטה נוספת של כב' המפקחת ענתבי שרון, מאותו יום, שלא ניתן לשלול את טענת בוף ובערוש באותו שלב של ההליך, לגבי כך שההסכמות נודעו להם רק עם הגשת הבקשה למחיקת תביעתם על הסף (ר' פסקה 9 להחלטה מיום 29.3.2020 בתיק בקשה 131/2019).

80. באשר לאופי ההסכמה הנדרשת להרחבת דירה על גבי הרכוש המשותף, נקבע בפסיקה שאין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, בין בכתב ובין בע"פ, ועל הצד הטוען להסכמה **מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיג את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק** [ר' רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402; ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78; באשר לצורך בהסכמה מפורשת הנדרשת לעניין ויתור על זכות הנובעת מבעלות בדירה בבית משותף ר' ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, נ"ד(3) 389, 394].

עוד נקבע בפסיקה שדיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי ונטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט [לעניין זה ר' לדוגמה רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן (נבו 23.2.12)].

81. טרם בחינת השאלה האם קיימים ממצאים עובדתיים אחרים מאלו שעליהם הסתמכה כב' המפקחת ענתבי שרון בהחלטותיה לעניין משך הזמן שחלף מאז התקבלה אצל התובעים ההחלטה לעניין ההרחבה, אציין שגם אם היה נמצא שחלפו יותר מ-30 יום, ספק אם היה בכך כדי לגרוע מזכותם של התובעים להגיש את התביעה. סעיף 71ג(ב) אינו מאיין את עצם זכותו של בעל דירה לקבל תשלומי איזון אם לא הגיש תביעה בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה, להבדיל מזכותו לטעון שתשלומי האיזון שקבע שמאי שמונה על ידי הצדדים אינם מקובלים עליו. זאת משום שסעיף 71ב(ד) קובע חובה לבעל הדירה המרחיב לשלם תשלומי איזון במועד החלטת ההרחבה, וכל עוד בעלי הדירות לא הגיעו להסכמה למינוי שמאי על -פי סעיף 71 ב(ה), עדיין לא מוצה נושא עצם התשלום. תוצאה על פיה מתקבלת החלטת הרחבה אולם בעלי הדירות, לרבות בעלי דירות שההחלטה התקבלה למרות התנגדותם, מנהלים מו"מ לגבי גובה תשלומי האיזון מבלי יכולת להגיע להסכמה, הנמשך למעלה מ-30 יום, תביא לאיזון זכותם של בעלי הדירות שאינם יכולים להרחיב דירתם באותו שיעור, לקבל תשלומי איזון, אינה סבירה [ר' לעניין זה החלטת כב' המפקח א' שלומאי בתיק (מפקח על רישום מקרקעין חולון) 121/21, 6/21, **יקוטי נ' מיקה** (טרם פורסם 5.9.2021, וכן פסק דינה של כב' המפקחת א' ארפי מוראי בתיק (מפקח על רישום מקרקעין פתח תקווה) 253/18 **וולקן נ' אוהבי** (נבו 14.11.2019)]. בענייננו, איני נדרשת להכרעה בעניין שכן כפי שיפורט להלן, לא מצאתי שחלפו למעלה מ-30 יום מאז התקבלה אצל התובעים ההסכמה האחרונה לביצוע ההרחבה על ידי התובעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

82. הנתבעים עצמם טענו שההסכמה הפוזיטיבית האחרונה שנדרשה לצורך גיבוש הרוב הדרוש להחלטת ההרחבה היא הסכמתו של ירקוני (ר' סעיף 30 לבקשת הנתבעים עמ' בן חמו וקיטנר לסילוק על הסף מיום 5.5.2019). טענה שבהמשך חזרו בהם ממנה במידה מסוימת. עמדתם זו של הנתבעים נבעה מכך שלגיבוש הרוב הדרוש על פי סעיף 71 **לחוק המקרקעין**, היה צורך בהסכמת 8 מתוך 10 בעלי דירות. בהתחשב בהסכם שנחתם עם בערוש בשנת 2016 ולאור הסכמת יתר בעלי הדירות למעט שמאי ובוף, נותר לשיטתם ירקוני כבעל הדירה השמינית שנדרשה הסכמתו (ר' סעיף 15 לתצהיר בן חמו לעניין קבלת הרוב הדרוש לביצוע ההרחבות). במאמר מוסגר אציין שמטענות בערוש עלה שהוא רואה עצמו כמי שהסכים לבניה רק עם הגשת התביעה על ידו, אולם איני מוצאת מקום לדון בטענה זו מכיוון שאני סבורה שגם אם הסכמת ירקוני היא ההסכמה שממועד הימסרה יש למנות את המועד להגשת התביעה, הרי ששתי התביעות הוגשו במועד.

83. מכאן, שככל שהנתבעים ביקשו להפריך את הבסיס העובדתי עליו התבססה החלטת כב' המפקחת (דאז) ענתבי שרון לעניין מועד קבלת ההחלטה, היה עליהם להוכיח שהסכמת ירקוני לביצוע ההרחבה נודעה לתובעים שמאי בוף ובערוש למעלה מ-30 יום לפני הגשת התביעות על ידם (סעיף 71ג(ב) **לחוק המקרקעין**).

אין מחלוקת שירקוני חתם על מסמך לעניין הסכמתו ביום 26.12.2016.

אמנם לטענתם המאוחרת של הנתבעים, ירקוני חתם קודם לכן על זיכרון דברים מיום 21.8.2016 (נספח במ 11 לתצהיר בן חמו משה) מול הנתבעים קיטנר ובן חמו אולם מהמסמך האמור (שצורף באופן חלקי) עולה ששני הצדדים התחייבו במסגרתו על חיסיון "מלא ומוחלט" ומתחייבים שלא להעבירו לצד שלישי ללא אישור בכתב מהצדדים, תוך קביעת פיצוי במקרה של הפרת תנאי המסמך, והנתבעים לא הוכיחו שהמסמך האמור הובא לידיעת מי מהתובעים. יתר על כן, המסמך צורף כאמור באופן חלקי בלבד לתצהירי הנתבעים (עמוד ראשון ואחרון בלבד) באופן שלא ניתן ללמוד ממנו האם באותו מועד אכן נתנה הסכמת ירקוני לביצוע ההרחבות, וכותרתו "זיכרון דברים". ההסכמות האחרות של ירקוני מול הנתבעים קיטנר בן חמו ועמר צורפו כנספח במ 10 לתצהיר בן חמו, ומהן עולה כי אז, 26.12.2016, הוסכם על העברת סך של 37,666 ₪ לירקוני תמורת העברת הזכויות. בנסיבות אלו, יש לראות את הסכמתו המפורשת של ירקוני לביצוע ההרחבות הנתבעים ככזו שנתנה ב-26.12.2016.

הנתבעים לא טענו שההסכם או זיכרון הדברים הובאו על ידם לידיעת התובעים, אלא שלטענתם התובעים, ובעיקר שמאי, ידעו על כך, והדבר נלמד לטענתם מנסיבות שונות כמו עיתוי המו"מ שלהם מול הנתבעים, מינוי שמאי מטעמם של התובעים שמאי בחודש יולי 2016, ומהעובדה שבהסכם של שמאי למכירת דירתו בדצמבר 2016 התייחס למחלוקת בעניין "תשלומי איזון" ועל כן ידע כבר אז שיש הסכמות להרחבה.

איני מקבלת את טענת הנתבעים בעניין זה. אין מחלוקת שהתובעים שמאי קיימו מו"מ עם הנתבעים לעניין הסכמתם להרחבה בין היתר בתמורה לדמי איזון, ואף בשלב מסוים עמדו לקראת כריתת הסכם בעניין. לפיכך הנסיבות שפורטו על ידי הנתבעים נובעות מאותו מו"מ, ולכל היותר יכולות להעיד על כך שהתובעים שמאי ידעו על עריכת מו"מ מקביל עם ירקוני, כמו גם עם בעלי דירות אחרים, אבל אין בכך כדי להעיד על ידיעתם על **ההסכמה** של ירקוני, מה גם שכאמור, הנתבעים הקפידו במסגרת המגעים מול ירקוני על דרישת חיסיון.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יתר על כן, המו"מ שנוהל בין הנתבעים לירקוני ובינם לתובעים, נוהל בסמוך לביצוע בפועל של הרחבת דירותיהם, כך שסביר שעובדה זו היא שהייתה הזרז העיקרי לניהול מו"מ בין הנתבעים לבין בעלי דירות אחרים מתוך אינטרס של הנתבעים לקבל את האישור הנדרש לביצוע העבודות.

חתימתם של הנתבעים במסמך זיכרון הדברים מול ירקוני על חיסיון, מחזקת את המסקנה שלא רק שלא הביאו את נושא המגעים מול ירקוני לידיעת התובעים, אלא פעלו כדי שגם ירקוני לא יעשה זאת.

84. הטענה שרוכש דירת שמאי השתמש לצורך הרחבת הדירה בזכויות ירקוני, ומכאן ששמאי ידעו על הסכמת ירקוני, לא הוכחה. אך גם אם אכן רוכש הדירה עשה שימוש בזכויות הבניה של ירקוני בהסכמתו, אין בכך כדי להביא למסקנה שהנתבעים שמאי ידעו על כך שירקוני הסכימו להרחבת דירות הנתבעים.

אין מחלוקת שלכל הצדדים זכות להרחיב דירותיהם בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף. אולם המחלוקת נשוא הליך זה נובעת מכך שהנתבעים הרחיבו את דירותיהם מעבר לחלקם היחסי ברכוש המשותף. הנתבעים אינם חולקים על כך, והדבר נלמד מהיקף הזכויות שנתנו במסגרת התב"ע, ואלו שהתבקשו בהיתרי הבניה של הנתבעים, ואף נבנו בפועל, כפי שאף עולה מחוות הדעת של השמאית מטעמי (ר' לדוגמה עמודים 8, 20, 23 לחוות הדעת). הרחבה עודפת כאמור, היא שמזכה בדמי איזון על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין.

כמו כן, על פי סעיף 71ב(א) ההחלטה לעניין הרחבה היא החלטה שצריכה להתייחס הן להצמדת חלקים ברכוש המשותף לצורך ביצוע ההרחבה והן לחלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה. מכאן שהסכמת בעלי הדירות לביצוע הרחבה כאמור, צריכה להתייחס גם להיבט של חלוקת זכויות הבניה.

בנסיבות האמורות, התנהלות הנתבעים אשר ניהלו מו"מ עם בעלי הדירות האחרים כדי לקבל את הסכמתם לביצוע ההרחבות, מצביעה על כך שגם הנתבעים הבינו שכל עוד לא נחתם הסכם עם בעלי הדירות האחרים, אשר כולל תשלום כספי לבעלי הדירות בגין אותן זכויות עודפות, הרי שאין הסכמה מטעמם לחלוקת הזכויות העודפות. לפיכך, משעה שהנתבעים הרחיבו דירותיהם בפועל מעבר לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לא הייתה שום מניעה שהנתבעים או ירקוני יעשו שימוש בזכויות מכח התב"ע לצורך הרחבת דירתם, באופן שאינו עולה על חלקם היחסי ברכוש המשותף, גם אם עדיין לא נתנו הסכמתם בהיבט של מתן זכויות הבניה העודפות לנתבעים. ניתן לראות בבניה כאמור לכל היותר הסכמה לניצול זכויות הנתבעים באופן שאינו עולה על חלקם היחסי ברכוש המשותף (הדבר עולה בקנה אחד גם עם הוראת סעיף 71ב(ג) לעניין הרחבה דומה).

85. טענת הנתבעים ששמאי מושתק מלטעון שלא ידע על הסכמת ירקוני כי שמאי עצמו דרש חיסיון במגעים מול הנתבעים נדחתה. ראשית, מהעובדה שגם במגעים מול ירקוני נדרש חיסיון מחזקת את טענת שמאי כי הדרישה באה מצד הנתבעים (ר' לעניין זה גם התייחסות לכך שהדרישה למיטב זכרוננו באה מצד הנתבעים בחקירתו בפרוטוקול הדיון מיום 28.12.201 עמוד 11 שורות 4-1), והדבר אף עולה ממיל שצורך כנספח 16 לתצהיר בן חמו, בו ציין התובע שמאי בפניה לנציג הנתבעים, ששמר על החיסיון בהתאם לדרישת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנית, על הנתבעים, במסגרת הנטל להוכיח קיומן של ההסכמות הנדרשות, להוכיח שהביאו את המידע בדבר היקף ההסכמות הנדרשות לבעלי הדירות האחרים, ללא קשר לפרטי ההסכמות או לבקשות בעלי הדירות האחרים כתנאי להסכמותיהם. לפיכך גם אם שמאי ביקש חיסיון אודות המגעים או ההסכמות המתגבשות כטענתם, אין בכך כדי להביא למסקנה שהנתבעים היו צריכים להסכים לדרישה כאמור, ובוודאי שאין בכך כדי לגרוע מחובת הנתבעים להביא את המידע הרלוונטי אודות קיומן של ההסכמות הנדרשות לשמאי ולבעלי הדירות האחרים כדי שיוכלו לממש זכותם להגשת תביעה לדמי איזון.

כדי להוכיח ידיעה של התובעים על ההסכמה של ירקוני, היה באפשרות הנתבעים להזמין את ירקוני למתן עדות בעניין. הנתבעים, אשר ביקשו תחילה לזמן את ירקוני לתת עדות, לא זימנו אותו בסופו של דבר. מכיוון שהנטל על הנתבעים להוכיח את טענתם לעניין מועד קבלת החלטתה על ההרחבה, הרי שאי זימונו של ירקוני למתן עדות פועל לחובתם של הנתבעים.

86. מכל מקום, בנסיבות העניין, שבהן המועד המוקדם יותר שבו התגבש הרוב הדרוש הוא 26.12.2016 בעת חתימת ירקוני, ולא קיימת כל הוכחה ברורה שהתובעים ידעו על כך אף לאחר שנתנה ההסכמה, הרי שהגשת התביעה על ידי התובעים שמאי חודשים ספורים לאחר מכן מצדיקה הארכת מועד על פי הסמכות הנתונה לי בסעיף 71(ב) למועד בו הוגשה בפועל, גם אם היה מוכח שלתובעים היה מושג כלשהו לעניין הסכמת ירקוני בסמוך לאחר חתימתו על ההסכמה.

87. באשר לתובעים בוף ובערוש, הנתבעים הודו שלא הביאו את הסכמת ירקוני לידיעתם (ר' חקירתו הנגדית של בן חמו, אשר פעל מול התובעים בוף ובערוש כנציג הנתבעים, בפרוטוקול הדיון מיום 3.1.2022 עמוד 24 שורה 50 עמוד 25 שורות 3-1). טענותיהם לעניין ידיעתם הן כלליות ונסיבתיות, ואינן מוכיחות ידיעה על ההסכמות (ר' לדוגמה סעיפים 31, 32 לתצהיר בן חמו).

לטענת בוף ובערוש, הם לא ידעו על הסכמת מי מבעלי הדירות, ונודע להם על כך לראשונה רק במסגרת כתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבעים. התובעים מצדם לא רק שלא הוכיחו שבוף ובערוש ידעו על הסכמת ירקוני טרם הגשת התביעה על ידם, אלא שגם לא הוכיחו על ידיעת בוף ובערוש אודות ההסכמות של בעלי דירות נוספים.

מכאן שלא הוכח שבעת שהוגשה תביעת בוף ובערוש, ידעו בוף ובערוש על החלטת ההרחבה. בהקשר זה חשוב לציין שהתובעים בוף ובערוש אינם מתגוררים בדירות שבבעלותם בבית המשותף, וגם משום כך לא היה מקום שהנתבעים יניחו שהם מודעים להסכמות בעלי דירות אחרים, בלי שהנתבעים יביאו את הדבר לידיעתם. אמנם בנם של בערוש וחתנו של בוף היו בקשר עם התובעים בזמנים שונים בנוגע לבנייה, אבל לא ניתן להסיק מכך שהיו מעודכנים בהיבטים הנוגעים להסכמות של בעלי דירות אחרים.

לאור כל האמור, אף שתביעת בוף ובערוש הוגשה ביום 18.2.2019, זמן רב לאחר שנתנה ההסכמה האחרונה המגבשת את הרוב הדרוש, הרי שהנתבעים לא הרימו את הנטל להוכיח שהסכמות הרוב הדרוש היו בידיעת תובעים אלו עד להגשת התביעה מטעמם, ועל כן טענת הנתבעים לעניין חלוף 30 יום מיום קבלת החלטת ההרחבה באופן המונע הגשת תביעה לדמי איזון, נדחתה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

88. לסיום עניין זה אתייחס לטענה נוספת שהועלתה על ידי התובעים שמאי בסיכומיהם אולם התייגרה לאור האמור לעיל. התובעים שמאי שטענו שהנתבעים פיצלו בפועל את דירותיהם בניגוד להיתר שניתן להם. לטענתם פיצול כאמור דורש הסכמה של 100% מבעלי הדירות ועל כן אין רלוונטיות למועד קבלת הסכמת ירקוני. דין טענה זו של התובעים שמאי להידחות. ראשית, מדובר בהרחבת חזית, כנטען על ידי הנתבעים, שכן התובעים שמאי העלו טענה זו לראשונה בסיכומיהם, ועל כן הטענה נדחת. שנית, הזכות לקבלת תשלומי איזון היא במקרה של הרחבת דירה בלבד. ככל שהנתבעים קיבלו הסכמות נדרשות להרחבת דירותיהם אולם ביצעו את הדבר בניגוד להיתר שניתן להם, הרי שעומדת זכות לבעלי הדירות האחרים לפעול בעניין בין אם בהיבטים התכנוניים ובין אם בהיבטים הקנייניים, אולם הסעד שהתבקש בהליך זה הוא תשלומי איזון, ובהקשר זה לא קיימת רלוונטיות לטענות בדבר פיצול הדירות.

הסכמים קודמים

89. תחילה יש להבהיר כי בנוגע לתובעים שמאי, לא נחתם הסכם לעניין דמי האיזון. אמנם נטען על ידי הנתבעים בן חמו קיטנר ועמר שנוהל מו"מ עם התובעים שמאי והצדדים לחצו ידיים, אך גם לשיטתם, התובעים שמאי חזרו בהם טרם חתימה על הסכם. מכאן שגם לשיטת הנתבעים כדי שהסכם כאמור יחייב את שמאי, היה צורך בחתימתם, אולם שמאי לא חתמו על ההסכם. הנתבעים טוענים ששמאי חזרו בהם ולא חתמו על ההסכם בשל דרישות משום שהנתבעים לא הסכימו לדרישות בלתי חוקיות שהעלו שמאי, אך אין בכך כדי לחייב את שמאי בהסכם שלא נכרת.

הסכם עם דהן לעניין החלל

90. מתצהירו של חיים דהן עולה כי לטענתו עוד בשנת 2004 מונה שמאי מטעם בעלי הדירות להעריך את שווי חלק הרכוש המשותף שהיווה חלל מתחת לדירתו, וגינה שהיתה במפלס אותו חלל, אולם לאחר שנתנה חוות דעתו של השמאי, לא התקבלה הסכמה לעניין מכירת השטח האמור על ידי יתר בעלי הדירות לדהן. בהמשך, ביקשו בעלי הדירות להציע את השטח האמור לקבלן, ודהן תבע אותם לדין תורה. בית דין צדק פסק שלאחר שיושג חוזה עם הקבלן, ייקבע דיון במסגרתו יוכלו דהן להתמחר עם הקבלן (ההחלטה צורפה כנספח 2 לתצהיר דהן). לטענתם, לאחר שנערך הסכם עם הקבלן והוסכם על מחיר, הסכימו דהן לשלם את אותו מחיר והתחילו ביישום ההסכם באופן פרטני כלפי בעלי הדירות.

91. **הסכם בין דהן לבערוש** – לטענת דהן, ביום 14.3.2006 חתמו על הסכם עם התובעים בערוש על פיו בערוש מכרו להם את זכויותיהם בשטח האמור תמורת \$6,000. ההסכם, ויפוי הכח שנחתם על ידי בערוש לצורך ביצועו צורף כנספח 4 לתצהיר דהן.

92. **הגינה - מעיון בהסכם עולה כי במסגרתו נמכר חלקם של בערוש ברכוש המשותף המוגדר כחלל אטום**. לטענת דהן, יש לפרש את ההסכם כמתייחס גם לגינה. לטענתם, דהן ביקשו מלכתחילה לעשות שימוש גם בגינה, ושהשמאי שמונה התייחס גם לגינה, והיא אף הוזכרה בנוסח ההסכם שנערך עם הקבלן. לטענתם, כאשר באו לחתום על ההסכם, בנם של בערוש סבר כי ההסכם עם הקבלן התייחס לשטח החלל בלבד וביקש לכתוב כך בהסכם, תוך שהוסכם בין הצדדים שאם יסתבר שההסכם עם הקבלן התייחס גם לשטח הגינה, ההסכם שבין דהן לבערוש יתוקן בהתאם. לטענת דהן, בשל החברות שלו עם בנם של בערוש, כאשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגיע לידיו ההסכם עם הקבלן וראה שאכן הוא מתייחס גם לגינה, סבר שהעניין סגור. בהסכם שנחתם לאחר מכן עם בעלי דירות אחרים אכן צוין גם החלל וגם הגינה, אשר נמכרו באותו סכום של \$6,000. בהמשך, כאשר הנושא עלה בין דהן לבערוש בשנת 2007, הובן כי קיימים חילוקי דעות בקשר לגינה.

בערוש מצדם טענו כי הסכמתם מותנית בכך שדהן לא יספחו שטחים נוספים לדירתם למעט החלל (ר' סעיף 8 לתצהיר דניאל בערוש), כן טענו שמכרו את שטח החלל במצבו כפי שהיה בעת המכירה, דהיינו ביעוד למחסנים וללא זכויות בניה אשר התווספו רק בהמשך.

מהאמור לעיל עולה שאכן נחתם הסכם בין דהן לבערוש, אך זאת בנוגע **לחלל בלבד**, ולא לגינה. ככל שהיה ברצון דהן להחיל את ההסכם גם על שטח הגינה, הרי שגם לשיטתם, היה צורך בתיקון ההסכם. לעניין זה ר' סעיף 18 לתצהיר דהן, בו הוא אמנם טוען שאם יסתבר שהסכם המכר עם הקבלן נעשה ביחס לגינה – יחול הדבר אוטומטית גם על ההסכם שבינו לבין בערוש, אולם מייד לאחר מכן הוא כותב "וזהו גם הסיבה לכך שהסכמנו שלא לציין תאריך על ההסכם, ולעדכן אותו בהמשך, ככל שיימצא שאני צודק" (ההדגשה אינה במקור, א.ש) מכאן שגם לדהן היה ברור שתוקף ההסכמה לגבי הגינה דורש תיקון של ההסכם. עניין זה נתמך גם בסעיף 21 לתצהיר דהן ממנו עולה כי כשנה לאחר מכן פנה אליו מיכאל בערוש ואמר שבכוונתו לבצע טקס חאלקה לבנו בגינה האמורה, ואז דהן אמר לו שהוסכם שהחצר שלו – ובערוש ענה לו בחריפות (הכוונה, שכעס על אמירת דהן שהחצר שלו). מכאן שגם דהן ידע, כבר אז, כשנה לאחר שנחתם ההסכם בו לא צויינה הגינה, שבערוש לא מסכים לפרשנות על פיה הגינה נמכרה לו. תגובתו של בערוש, שהובאה על ידי דהן עצמו, מחזקת את המסקנה שלא היתה כל הסכמה מפורשת של בערוש למכור את הגינה לדהן.

לסיכום עניין זה, כפי שנאמר לעיל, על פי הפסיקה הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה מסוימת צריכה להיות ברורה ומפורשת, ועל הצד הטוען לקיומה של הסכמה כזו, הנטל להוכיח את קיומה. בענייננו, קיימת הסכמה בכתב של בערוש לעניין החלל בלבד, לפיכך לא די בפרשנות שנתן דהן להסכמות שבינו לבין בערוש כדי להביא למסקנה שבערוש הסכימו במפורש לויתור על הגינה, ובכל מקרה דהן לא הרימו את הנטל להוכיח זאת.

זכויות הבניה - ההסכם שנחתם לא התייחס כלל למכירת זכויות הבניה במסגרתן הרחיב דהן את דירתו, שכן דהן לא טענו, וממילא לא הוכיחו שהיו קיימות זכויות בניה באותה עת. מטענות הצדדים עולה שזכויות הבניה נוספו רק לאחר אישור התב"ע שקידמו דהן עם הנתבעים האחרים בשנת 2012. יתרה מכך, כפי שעלה מחקירתו הנגדית של דהן, היה בכוונתו להכשיר את השימוש באותו חלל כמחסנים, אולם בפועל הדבר לא אושר במסגרת ההיתר שקיבל עקב התנגדות בערוש, ובפועל החלל האמור סגור (ר' פרוטוקול הדיון מיום 3.1.2022 עמוד 23 שורות 25-3). מכאן, שאין קשר בין החלל האמור לזכויות הבניה הנוספות נשוא הליך זה.

משמעות העברת הזכויות בחלל - עוד עולה מההסכם נספח 4 שבערוש התחייבו במסגרת ההסכם עם דהן לחתום על כל המסמכים הדרושים לצורך רישום להעברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין על שם דהן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מכיוון שאין מחלוקת שהחלל האמור היה רכוש משותף, הרי שהאפשרות להעבירו לבעלות דהן היא באחת משתי דרכים. או בביצוע הצמדה של השטח האמור לדירת דהן בהסכמה של 100% מבעלי הזכויות על פי סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, או בהצמדתו הפיזית לדירת דהן באופן שיהווה הרחבת דירה, ברוב הדרוש על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין.

חתימת בערוש על ההסכם האמור, מהווה הסכמה מטעמם, שאינה מספיקה לביצוע הצמדה או להרחבת דירת דהן, אלא לאחר גיבוש הרוב הדרוש. אף אם מדובר בהרחבת דירת דהן, באופן המצריך רוב מופחת מ-100% מבעלי הדירות, הרי שבמועד חתימת בערוש על ההסכמה לא היה בידי דהן הרוב הדרוש. מכאן, שגם הסכמת בערוש להעברת הזכויות בחלל לדהן אינה מספיקה כדי להביא למסקנה שאותן זכויות הועברו בפועל.

93. מכל האמור עולה, שאמנם קיימת הסכמה של בערוש משנת 2006 להצמדת החלל, שעליה קיבלו תמורה, אולם אין בהסכמה האמורה כדי להביא להעברת הזכויות בחלל לדהן, כל עוד לא התגבש הרוב הדרוש לכך, ובכל מקרה אין בה כדי להביא לויתור של בערוש על **זכויות הבניה** שנתנו במסגרת התב"ע שאושרה מאוחר יותר, אשר אפשרו להרחיב את דירת דהן ללא קשר לחלל האמור.

מכיוון שבערוש מבחינתם, ויתרו על זכותם בחלל עצמו, וקיבלו על כך תמורה, תוך שדהן הסתמכו על כך ושינו מצבם לרעה תוך שהוציאו הוצאות נוספות כדי לקבל הסכמות של בעלי דירות אחרים, הרי שמבלי לקבוע מסמרות בעניין, יכול הדבר להביא למסקנה שבערוש אינם רשאים לחזור בהם מהסכמה זו. אולם הסכמה זו נוגעת לחלל בלבד, כאשר כעולה מהאמור לעיל, לא נכלל בהיתר הבניה שניתן לדהן לצורך הרחבת דירתם. מכאן שאין לגרוע את התשלום ששולם לבערוש מתשלומי האיזון המגיעים להם בשל הזכויות הנוספות, שאינן מתייחסות לאותו חלל, שקיבלו דהן בעקבות התב"ע והיתר הבניה.

94. לא קיים הסכם בין דהן ליתר בעלי הדירות ובכללם בוף ושמאי - לטענת דהן, יתר בעלי הדירות לא הסכימו להסתפק בסך של \$6,000 ודרשו סכום גבוה יותר. לטענתם הייתה בכך הפרה של ההסכם וגם הפרה של החלטת בית הדין.

אין בידי לקבל את הטענה על פיה נסיבות החלטת בית הדין בשנת 2006 מעידות על קיומו של הסכם מול בעלי הדירות. כאמור, הסכמת בעלי דירות להוצאת חלקים מהרכוש המשותף ולהצמדתם לדירה מסוימת צריכה להיות ברורה ומפורשת. במקרה דנן, למעט התובעים בערוש אשר חתמו על הסכמה בשנת 2006 למכירת חלקם היחסי בחלל לדהן, התובעים האחרים, דהיינו שמאי ובוף מעולם לא חתמו על הסכמה כזו.

הגם שהתנהל מו"מ בין דהן לבין בעלי דירות אחרים לעניין ויתור על זכויותיהם בחלל ובגינה, דהן לא הוכיחו כי המו"מ האמור הבשיל מול שמאי ובוף להסכם מחייב. מטענות דהן עצמן עולה כי פעלו במהלך השנים מול בעלי הדירות בבית המשותף לחתימת הסכם לצורך הסדרת העניין, וכי רק חלק מבעלי הדירות חתמו על הסכם כאמור, ובכללם בערוש אשר חתמו על ההסכם בשנת 2006. מכאן שדהן עצמם סברו שיש צורך בחתימה על הסכם לצורך הצמדת הזכויות בחלל לדירתם, ולא די בנסיבות שתוארו על ידם כדי להעיד על קיומו של הסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גם החלטת בית הדין נספח 2 לתצהיר דהן אינה מועילה בהקשר זה שכן היא מתייחסת להליך שבין דהן לבין בעל דירה אחר, וויינפראד, שכלל אינו צד להליך זה, אך שימש באותה עת כנציג נציגות הבית המשותף, וכל שנקבע בה הוא זימון הרוכש (הקבלן שהביע רצון לרכוש את הזכויות בחלל ובגינה) ודהן להתמחרות. גם בהתחשב בכך שאותו וויינפראד היה נציג נציגות הבית המשותף, הרי שלא היה יכול, על פי דין, להסכים כנציג הנציגות על העברת זכויות ברכוש המשותף לדהן, ללא הסכמה של כל בעלי הדירות כנדרש בסעיף 62(א) לחוק המקרקעין, אשר כפי שנאמר לעיל, על פי הפסיקה הסכמה כאמור צריכה להיות ברורה ומפורשת. דהן, אשר הנטל עליהם להוכיח הסכמה כאמור, לא הוכיחו זאת.

יתר על כן, מטענות דהן לא עולה כי התבצעה התמחרות כאמור בהחלטת בית הדין, אלא שלאחר מכן פנו הם, דהן, באופן נפרד לבעלי הדירות כדי לרכוש מכל אחד מהם בנפרד את חלקו כדי לקבל את הסכמתו להעברת הזכויות. הדברים נתמכים גם בחקירתו הנגדית של מיכאל בערוש אשר השיב שאינו זוכר שנתבע על ידי דהן בבית הדין ולא ידע כלל על החלטת בית הדין או על הנוסח שגובש לגבי הסכם עם הקבלן (ר' פרוטוקול הדיון מיום 28.12.2021 עמוד 3 שורות 43-46, עמוד 4 שורות 1-15).

הדברים אף נתמכים בחקירתו הנגדית של דהן עצמו שהודה שמי שחתם על שטר הבוררות היה רק נציג ועד הבית, וינפראד, אשר טענת דהן פעל בשם בעלי הדירות (פרוטוקול הדיון מיום 3.1.2022 עמוד 16 שורות 1-4), והוא זה שהופיע בפני בית הדין (עמוד 18 לפרוטוקול שורות 49-40), וכן הודה שלא בוצעה התמחרות כפי שדרש בית הדין אלא שהציע לבעלי הדירות את אותו מחיר שהציע הקבלן (עמוד 19 לפרוטוקול שורות 23-21).

מכאן שגם דהן לא ראה באותן נסיבות משום הסכמה של בעלי הדירות לתת לו את החלל ואת הגינה, וסבר שעליו להגיע להסכמים נפרדים עם כל אחד ואחד מהם.

מכל מקום, כאמור, נדרשת הסכמה מפורשת של בעלי הדירות עצמם לצורך ויתור על חלקם בחלקים מהרכוש המשותף לצורך הצמדתם לדירה מסוימת, והסכמה של נציג הנציגות, גם אם הייתה קיימת, אינה יכולה לחייב את בעלי הדירות האחרים.

לא קיים כל הסכם חתום בין דהן לבין התובעים בוף ושמאי, וכאמור, אין די בנסיבות שפורטו על ידי דהן כדי להביא למסקנה שבוף ושמאי הסכימו באופן ברור ומפורש להצמדת החלל לדירת דהן. להיפך, מחקירתם עלה שדהן ניסה לשכנע אותם לרכוש את חלקם בחלל האמור תמורת \$6,000 אולם הם לא הסכימו לכך (ר' לדוגמה חקירתו הנגדית של שמאי בפרוטוקול הדיון מיום 28.12.2021 עמוד 7 שורות 46-50, עמוד 8 שורות 1-28). מכאן שדהן לא הוכיחו כי במועד כלשהו נכרת הסכם בינם לבין שמאי או בוף לעניין העברת הזכויות בשטחים האמורים.

95. לאור האמור, גם טענת דהן לקיומו של הסכם משנת 2006 לעניין העברת חלקם של בוף ושמאי ברכוש המשותף לדהן נדחתה.

הסכם בין בערוש להתובעים קיטנר ועמר ובן חמן

96. ביום 31.10.2016 נכתב סיכום פגישה בין בן חמן לבערוש (נספח ח לתצהיר בערוש, נספח 12 לתצהיר בן חמן) על פיו בן חמן קיטנר ועמר יסייעו לבערוש יעשו הכל כדי שבערוש יוכלו להרחיב דירתם בהתאם לתב"ע ובכלל זאת החתמת שכנים ובניית מעטפת עמודים בדירת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בראון, זאת תמורת הבנייה שביצעו בן חמו קיטנר ועמר על הגג. ביום 18.12.2016 נכתב סיכום פגישה נוסף בין בערוש לעמר קיטנר ובן חמו (נספח ט לתצהיר בערוש, נספח 12 לתצהיר בן חמו), הכולל סיכום דומה לאמור לעיל וכן סיכום בנוגע לסיוע מול משפחת דהן בנוגע להשתתפות בעלויות בגין בניית היסודות על ידי דהן, כל זאת כדי לאפשר בניה על ידי בערוש. בתמורה לנ"ל הסכימו בערוש לוותר לקיטנר עמר ובן חמו על הבניה שביצעו על גג הבית המשותף והצמדת השטח לטובתם. עוד נאמר בסיכום הפגישה כי קיטנר עמר ובן חמו מוותרים על טענות כלפי בערוש לעניין הבניה ולעניין תשלום חלקם היחסי בעלות חיזוק הגג וחיזוק הבניין כל זאת אם לא תהיה תביעה משפטית מטעם בערוש. מי שפעל בשם בערוש בניהול המו"מ ונכח בפגישות הוא בנם, בנימין בערוש.

97. לטענת הנתבעים קיטנר עמר ובן חמו, סיכומי הפגישות הנ"ל מהווים למעשה הסכם בינם לבין בערוש לעניין הסכמת בערוש להרחבות שבוצעו על ידם וויתור על דמי האיזון.

98. לטענת בערוש, הסכמתם לוותר על דמי איזון הותנתה בכך שיוכלו להרחיב את דירתם בסמוך לאחר מכן, ולכל היותר מדובר בהסכם המותנה בתנאי, והתנאי לא התקיים (ר' לדוגמה חקירתו הנגדית של בנימין בערוש שניהל את המו"מ בשם הוריו, התובעים בערוש, בפרוטוקול הדיון מיום 28.12.2021 עמוד 20 שורות 27 – 39, עמוד 21 שורות 7-2 עמוד 22 שורות 4-6).

99. אין מחלוקת כי בפועל ברעוש לא פעלו להוצאת היתר בניה ולא ביצעו הרחבה של דירתם עד היום. טענת הנתבעים היא שברעוש הם שהכשילו את קיומו של ההסכם בכך שלא פעלו להוצאת היתר להרחבת דירתם.

100. במכלול הנסיבות, אני סבורה שלא ניתן לפרש את המסמכים האמורים באופן המביא למסקנה שבערוש ויתרו במסגרת המסמכים האמורים על דמי האיזון, אלא שהצהירו על כוונתם לוותר על דמי איזון כאמור רק עם ביצוע הרחבה של דירתם בפועל, ככל שתוכל להתבצע בתנאים מסוימים. להלן אנמק.

ראשית, מאופן ניסוח המסמכים האמורים נראה שלא הייתה כוונה להגיע להסכם סופי ומחייב בהיבט של דמי האיזון. מדובר במסמכים שכותרתם "סיכום פגישה" שנכתבו על ידי הנתבעים, ומנוסחים בשפה שאינה משפטית. המסמך מיום 31.10.2016 כתוב בכתב יד שאינו של בערוש, אינו חתום ומחקירתו הנגדית של בנימין בערוש עולה ספק אם ראה אותו בסמוך לאחר שנכתב (ר' פרוטוקול הדיון מיום 28.12.2021 עמוד 20 שורות 30-23). אמנם המסמך מיום 18.12.2016 חתום על ידי בערוש (וכן על ידי קיטנר ובן חמו), אך האופן בו נוסח, בכל הנוגע לויתור של בערוש על זכותם בגין בניית הנתבעים, מתאים יותר להצהרת כוונות מאשר להסכם מחייב. כך לדוגמה נכתב "משפחות קיטנר עמר ובן חמו מתחייבים **לסייע** ככל שנדרש למשפחת ברוס על מנת שהשכנים יחתמו על הטפסים של בקשת ההיתר בניה למשפחת ברוס ולסייע לכך שהיתר הבנייה יתממש בפועל... ומשפחות קיטנר עמר ובן חמו **ינסו להגיע** להסכם עם משפחת ברוס, הן בנוגע לרצון לבנות והן בנוגע לתשלום על הבניה, תוך חודש ממועד חתימת הסכם זה..." וכן "משפחות קיטנר עמר ובן חמו **יסייעו** לברוס שמשפחת דהן לא תדרוש ממשפחת ברוס יותר מרבע עלות היסודות..." וכן "כמו כן משפחות עמר קיטנר ובן חמו לא יגיעו להסכם עם משפחת דהן בדבר ויתור על דמי איזון זכויות בניה כל עוד לא יתאפשר למשפחת ברוס היכולת לבנות כתוצאה ממניעה של הבניה מצד משפחת דהן" (ההדגשות אינן במקור, א.ש).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שנית, גם ממסמכים אלו עולה כי הוויתור של ברעוש על דמי האיזון יהיה רק עם ביצוע בפועל של הבניה. בסיכום הפגישה מיום 18.12.2016 נכתב "משפחת ברוס מסכימה תמורת כל הנ"ל, **ובתנאי שהבנייה אכן תבוצע מייד אחרי קבלת ההיתר בנייה**, לוותר על טענות כלשהן כלפי משפחות קיטנר עמר ובן חמו הן בבית דין והן בבית משפט על הבניה שמשפחות קיטנר עמר ובן חמו בנו..." (ההדגשה אינה במקור, א.ש). כמו כן נכתב שככל שהבנייה לא תוכל להתחיל חודשיים לאחר מתן היתר בנייה או שלא תוכל להסתיים מכל סיבה שהיא, הצדדים יקיימו פגישה נוספת וברעוש יוכלו להחליט האם הם מנסים לקדם את העניין ומוותרים על הטענות כלפי הנתבעים.

מכאן, שהתנאי לויתור בערוש על טענות כלפי הנתבעים קיטנר עמר ובן חמו היה שבערוש לא רק יוכלו לבצע בניה של הרחבת דירתם, אלא יבצעו את הבניה בפועל. לצורך כך, כעולה מהמסמך האמור, היה צורך בהתקיימות מספר תנאים, שכולם כפופים לביצוע הבניה כאמור לעיל. האחד, חתימת השכנים על בקשה להיתר בניה של בערוש. השני, מימוש ההיתר בפועל, ובכלל זאת, שאם ההיתר יהיה תלוי בביצוע הרחבה על ידי השכן בראון מתחת לדירת בערוש, הנתבעים ינסו להגיע עמו להסכם הן בנוגע לרצון לבנות והן בנוגע לתשלום על הבניה. השלישי מתייחס לסיוע של הנתבעים בן חמו עמר וקיטנר בכך שהנתבעים דהן לא ידרשו מהם יותר מרבע מעלות היסודות שבנו דהן ושלא יהיה עיכוב מצד דהן לבניה של בערוש.

מהמסמך עולה כי נושא הרחבה בפועל של דירת בערוש היה עניין מהותי במסגרת סיכום הפגישה.

גם אם הסיבה לכך שהבנייה בפועל של הרחבת דירת בערוש לא החלה, ואף לא התבקש היתר בנייה, היא באחריות בערוש, כטענת הנתבעים, ולא בשל היעדר סיוע מצדם, לכל היותר הנתבעים יכולים לטעון להפרת הסכם על ידי בערוש אך אין בכך כדי להביא למסקנה שיש לאכוף את ההסכם האמור, כאשר הנסיבות הנדרשות לויתור מצד בערוש על דמי האיזון לא התקיימו.

הצדדים חלוקים בעניין קיומה של הסכמה של השכן בראון, שהצדדים ראו בה היבט משמעותי ליכולת בערוש להגיש בקשה להיתר בניה ולבצע הרחבה של דירתם. לטענת בערוש, השכן בראון לא הסכים לביצוע ההרחבה ולכן לא היה טעם שיפעלו להגיש בקשה להיתר בניה לביצוע הרחבה מעל דירתו. לטענת הנתבעים בן חמו עמר וקיטנר, בראון לא התנגד לבניה מעליו, אך ביקש שישאירו לו פינה לא מקורה למרפסת סוכה, ובן חמו הודיע על כך בשיחה לבערוש, והיה באפשרות בערוש להגיש בקשה להיתר ובמסגרתה לבקש לבנות עמודים על גבי המעטפת שבנו דהן מתחת לבראון. לטענתם, רק אם בראון היה מגיש התנגדות לבקשה כזו, ניתן היה לטעון להפרה של הנתבעים את ההסכם (תצהיר בן חמו סעיפים 25-21).

אולם מ-2 מסמכי ההסכמות ניתן להבין שהכוונה בצורך בהסכמת בראון הייתה בין היתר להכנת תשתית (עמודים או מעטפת) **בקומת דירת בראון** ללא עלות לבערוש (כך לדוגמה נכתב בסיכום מיום 31.10.2016 – שבערוש דורשים מהנתבעים לעשות הכל כדי שהיא תוכל לבצע את ההרחבה בפועל "דהיינו הוצאת היתר בניה כולל החתמת השכנים והבניה בפועל כולל בניית מעטפת או עמודים למשפחת ברוס כדי לאפשר את הבניה למשפחת ברוס...").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אולם בפועל עולה כי לא נבנתה מעטפת או עמודים בקומת בראון, אלא שלטענת הנתבעים, בערוש יכלו לבקש במסגרת בקשה להיתר לבנות עמודים כאלו. כמו כן בראון לא הוזמן על ידי הנתבעים לתת עדות, וגם מעדות הנתבעים עצמם עולה שהסכמתו כללה לכל היותר הסכמה לבניה של בערוש על חלק מהשטח הניתן להרחבה, שכן גם לשיטתם ביקש להשאיר שטח מסוים ללא בניה כדי שיוכל לבנות סוכה. לפיכך, טענת הנתבעים שפעלו מול בראון למתן הסכמתו ולכך שגם הסכים לבניית בערוש מעליו, לא הוכחה על ידם.

כמו כן עולה שההסכמה הייתה שהנתבעים ינסו להגיע להסכמה עם בראון **תוך חודש** מחתימת המסמך מיום 18.12.2016, אך לטענת בנימין ברעוש, ממועד החתימה על אותו מסמך הנתבעים נתקו עמו קשר ולא סייעו בקבלת אותה הסכמה (סעיף 41 לתצהירו בנימין ברעוש). לטענתו, לא הייתה לנתבעים כוונה כלל לסייע לו בעניין, אלא להשתיק אותו, כדי שלא יפריע להם בביצוע ההרחבות שביצעו במקביל (סעיף 42). לטענתו עד היום לא נתנה הסכמת בראון (סעיף 43).

בהקשר זה אני נותנת אמון בדברי בנימין ברעוש בחקירתו הנגדית, לכך שהכוונה הייתה לוותר רק לאחר ביצוע בניה בפועל (ר' פרוטוקול הדיון מיום 28.12.2021 עמוד 21 שורות 5-7), ולכן שמצדו פעל כדי לקדם את סיכום הדברים אולם לא זכה לשיתוף פעולה מצד הנתבעים. בנימין ברעוש הסביר בחקירתו הנגדית שלמעשה כוונתו הייתה להביא לכך שבראון יבנה מתחתם כך שיתאפשר להם לבנות מעליו אולם בראון סרב לכך, וניסיונותיו לקבל תשובות בעניין מבן חמו לא צלחו שכן בן חמו לא חזר אליו (עמוד 21 שורות 8-50, עמוד 22 שורות 1-6). מחקירתו הנגדית של בן חמו עולה שאינו מכחיש שלא חזר לבערוש בעניין אף לאחר מייל ששלח אליו בינואר 2017, אלא שלטענתו פגש את בערוש לאחר מכן במדרגות ואמר לו בעל פה שבראון מסכים ושיגיש בקשה להיתר בניה ובראון יחתום לו (עמוד 25 שורות 20-31). גרסה זו תמוהה, שכן עולה שבערוש הוא שניסה לקדם את האמור במסמכים, בעוד בן חמו, שהיה בעל האינטרס המשמעותי להראות שהדברים אכן מקודמים, לא מצא לנכון לעדכן את בערוש בכתב, אלא רק בפגישה מקרית בחדר המדרגות, שלא ידוע מתי התקיימה, אולם לטענתו התקיימה לאחר מייל ששלח אליו בערוש בבקשה לעדכון דחוף מינואר 2017. גם אז לא טען בן חמו שנתן אסמכתה להסכמת בראון הנתענת, אלא אמר שהסכמת בראון תינתן רק לאחר שתוכן בקשה להיתר בניה מטעם בערוש (דהיינו, לאחר שייכנסו להוצאות לצורך כך). מכל מקום, גם מדברים אלו של בן חמו, לא ניתן להבין מתי היה המפגש הנטען בחדר המדרגות, ולכך שהניסיונות לקבל את הסכמת בראון היו בתוך חודש כפי שהוסכם בין הצדדים.

גרסת בערוש מהימנה עלי גם בהתחשב בכך שבתקופה בה הסכים על הדברים בשם הוריו הוא היה בחור צעיר כבן 25, אשר לא לקח ייצוג משפטי, ולא היה בקיא בהיבטים המשפטיים, כפי שגם עולה מהתנהלותו מול ועדות התכנון (ר' עמוד 17 לפרוטוקול הדיון שורות 7-30) בעוד הנתבעים פעלו לאורך מספר שנים לקדם את אישור התב"ע והיתרי הבניה בסיוע של אנשי מקצוע רבים ובכללם אדריכל ועו"ד, כך שמבחינת הבנת זכויות הצדדים ידם הייתה על העליונה. לפיכך אני סבורה שאף הנתבעים הבינו, בזמן שנוסחו ההסכמות, שכוונת בערוש היא כפי שנטען על ידו, אולם העמימות שבניסוח הדברים הייתה נוחה להם, שכן, כפי שטענו בערוש, רצו להמשיך בביצוע הרחבות הבנייה שלהם, שכבר החלו בפועל, ללא הפרעות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מכל מקום, לא סביר לפרש את ההסכם כך שבערוש הסכימו לוותר על דמי איזון בגין הרחבת דירות הנתבעים, בתמורה לסייע בלבד של הנתבעים מול השכן כדי שההרחבה תתאפשר, מה גם שלא נכתב באופן ברור במה כרוך אותו סיוע. הפרשנות הסבירה יותר היא ששני הצדדים ראו בביצוע הבנייה בפועל תנאי מהותי לוותר ברעושו על דמי האיזון, ועל כן הנתבעים, שכמובן לא יכלו להתחייב בשם השכן בראון שלא היה צד לעניין, על הסכמה לבנייה מעליו ללא תשלום, התחייבו לסייע בכך כדי להביא לתוצאה ששני הצדדים קיוו לה.

שלישית, הנתבעים לא טענו כי שינו באופן כלשהו את מצבם לרעה בשל ההסכמות נשוא המסמכים. הנתבעים ממילא בצעו את ההרחבות, וככל שסייעו לבערוש להשיג את ההסכמות להרחבת דירתם, או שהפנו אותם לאדריכל כדי שסייע להם בהוצאות היתר בניה (במימון בערוש) לא היה בכך כדי לשנות את מצבם של הנתבעים לרעה. להיפך, ככל שלבערוש אפשרות לבנות הרחבה גדולה יותר, כך הדבר מפחית מתשלומי האיזון שעל הנתבעים לשלם להם, כך שהאינטרס לסייע לבערוש לבצע הרחבה משותף לשני הצדדים.

רביעית, בסיכום הפגישה מיום 18.12.2016 נכתב כי הסכמת הנתבעים לוותר על טענות לעניין הרחבת הבניה שיבצעו ברעושו מותנית בכך שבערוש לא יגיש תביעה כלפיהם. מכאן שגם הנתבעים לא ראו בהסכמות שבמסמך ויתור סופי של שני הצדדים על טענות זה כלפי זה, וצפו את האפשרות שההסכמות לא יצאו לפועל ובערוש יגישו תביעה.

101. מהאמור עולה שלכל היותר הנתבעים היו רשאים להבין משני המסמכים שנחתמו, שבערוש מסכימים להרחבות שבוצעו על ידי הנתבעים (ואף זאת לא באופן חד משמעי), ושבהתקיים תנאים מסוימים, יסכימו לוותר על דמי האיזון. בפועל אין מחלוקת שהתנאים לא התקיימו, ולכל היותר אולי ניתן לטעון כלפי בערוש שתרמו לאי קיומם של התנאים, באופן שהביא להיעדר אפשרות לביצוע ההסכם, אך בכך שאין מחלוקת על כך שהרחבת דירת בערוש לא בוצעה בפועל, ובודאי לא בלוחות הזמנים שצויינו במסמכים האמורים, לא מתקיימות נסיבות בהן ניתן לאכוף על בערוש לוותר על דמי האיזון.

לא קיים הסכם בין בוף לקיטנר עמר ובן חמו

102. לטענת הנתבעים, בין נציגו של בוף לבנים שהנתבעים יוותרו על חלקו של בוף בעלות הפרויקט ויאפשרו לו שימוש במעלית והוא יוותר על תביעות כספיות ובכללן דמי איזון. בתצהירו של מוריס בוף, ובתצהיר חתנו, גרבלי, נטען שהוצעו הצעות מסוג זה על ידי בן חמו מול גרבלי במסגרת הצעות לפיצוי בגין הבניה שביצעו הנתבעים, אולם הובהר מטעם בוף כי הם מצפים לפיצוי משמעותי יותר, ובהמשך בן חמו אף הבהירו כי גם ההצעה האמורה כבר אינה רלוונטית (סעיף 13 לתצהיר בוף, סעיף 11, 12 לתצהיר גרבלי). לטענתם, הסכמתם לבניה נעשתה רק עם הגשת התביעה (סעיף 18 לתצהיר בוף). האמור בתצהירים לא נסתר.

גם מתצהיר בן חמו עצמו עולה שהציע הצעות לגרבלי כנציגו של בוף בעניין אולם גרבלי לא חזר אליו, בן חמו טען בכלליות שגרבלי "נתן לו את הרושם שזנח את העניין" (סעיף 34 לתצהיר בן חמו, וכן תשובותיו בחקירתו הנגדית מהן עולה כי מעולם לא נתנה מטעם בוף הסכמה לכך שהמעלית תהווה פיצוי בגין הבניה העודפת – ר' פרוטוקול הדיון מיום 3.1.2022 עמוד 24 שורות 46-49, עמוד 25 שורות 4-11). מחקירתו של בן חמו עלה שהסיק שבין מסכימים לבניה בלי שבכלל שאל אותם על כך, משום שגרבלי, חתנם, ניהל מ"מ



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעניין הפיצוי שיינתן להם. אולם כאמור, בהתאם לפסיקה, הסכמה כאמור להוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה, צריכה להיות מפורשת, ואף מחקירת בן חמו לא עלה כי מדובר בהסכמה מפורשת. מה גם שהנתבעים כלל לא טענו שדיברו עם בוף באופן ישיר, אלא עם גרבלי, חתנם, שניהל את המו"מ מטעמם, ואף הבינו כי נדרשת הסכמה של בוף עצמם לצורך הסכם מחייב, הסכמה שלא נטען שנתנה.

משכך, טענת התובעים בוף שהבהירו לבן חמו, כנציג הנתבעים קיטנר עמר ובן חמו, שהסכמתם לבניה מותנית בפיצוי הולם (ר' לדוגמה סעיף 10 לתצהיר גרבלי מטעם בוף) היא שמתיישבת עם ההיגיון ועם יתר הנסיבות.

103. מהאמור עולה כי הנתבעים לא הוכיחו שבוף נתנו בשלב כלשהו את הסכמתם לביצוע ההרחבות או לויתור על דמי האיזון.

הפחתת היטל השבחה

104. בהחלטתי מיום 30.12.2021 קבעתי כי על השמאית מטעמי לתת חלופות במסגרת חוות דעתה לעניין גובה דמי האיזון, הן בהתייחס לאפשרות של ניכוי היטל השבחה **תיאורטי** שהיה על התובעים לשלם בגין הזכויות שקיבלו, והן לאפשרות של ניכוי הסכומים ששילמו **בפועל**, בהתחשב בפטורים שקיבלו. מכיוון שמדובר במחלוקת משפטית, נקבע שזכות הצדדים לטעון בעניין זה בסיכומיהם, כמו בעניינים משפטיים נוספים העולים מחוות דעתה של השמאית מטעמי, כך שההכרעה בעניין תינתן במסגרת פסק הדין. באשר לטענות אחרות שהעלו הנתבעים טרם מתן ההחלטה בעניין זה, נתנה הכרעה במסגרת אותה החלטה.

105. לטענת התובעים, אמנם יש לנכות את סכומי היטל השבחה לצורך חישוב תשלומי האיזון, אך זאת ביחס לסכומים ששילמו הנתבעים בפועל, ולא ביחס לסכומים תיאורטיים מקסימליים שאינם מתחשבים בפטורים שנתנו להם. לטענת הנתבעים, הפטור שניתן להם על פי סעיף 19(ג) לתוספת השלישית **לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965** (להלן – חוק התכנון והבניה), הוא פטור אישי, הניתן לכל אדם פעם אחת בחייו, ועל כן בעתיד לא יוכלו לנצל אותו, וכן אם לא יעמדו בתנאי הפטור, יידרשו להשיב את הסכומים. בנוסף לטענתם, השמאי המכריע שדן בהיטל השבחה בבית המשותף, בחר בגישה הלוקחת בחשבון שקיימת חבות בהיטל השבחה עקב אישור התוכנית.

106. בעניין זה אני מקבלת את עמדת התובעים, וקובעת שהחלופה על פיה נלקחו בחשבון סכומי היטל השבחה ששולמו **בפועל**, היא החלופה הרלוונטית לעניין חישוב דמי האיזון. להלן אנמק.

107. סעיף 19(ג) לתוספת השלישית **לחוק התכנון והבניה** קובע:

"(1) בניה או הרחבה של דירת מגורים לא ייראו כמימוש זכויות אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 140 מ"ר; עם כל בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(2) העברת הבעלות או החזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור בפסקה (1) או שניתן להרחיבה לפי תכנית, לא יראו כמימוש זכויות ולא תחול בגינה חובת תשלום ההיטל, אם המחזיק במקרקעין או קרובו השתמשו בדירה למגוריהם או למגורי בני משפחתם הקרובים מגמר הבניה ועד מכירתה משך זמן שאינו פחות מארבע שנים; לענין זה, "גמר הבניה" – כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961.

108. הרציונל לקיוזו היטל השבחה משווי הזכויות העודפות לצורך קביעת דמי איזון הוא שאם בעל הדירה המרחיב את דירתו שילם הוצאות ישירות לצורך קבלת זכויות אלו, הרי ששווי הזכויות צריך לקחת בחשבון תשלום כאמור, שאחרת בעל הדירה המרחיבה יצא נפסד במסגרת איזון הזכויות, שכן ישלם תשלום העולה על שווי הזכויות "נטו" כפי שהתקבל על ידו. מנגד, בעל הדירה שאינו יכול להרחיב את דירתו באותו אופן, מקבל במסגרת תשלומי איזון את חלקו היחסי בשווי הזכויות הנוספות, ואינו נדרש לשלם על כך היטל השבחה. לפיכך, ככל שלא יקוזז הסכום ששולם על ידי בעל הדירה המרחיבה, יוצר מצב שבו בעל הדירה האחרת יתעשר על חשבונה.

אולם כאשר בעל הדירה המרחיבה קיבל בפועל פטור מהיטל השבחה, הרי שלא נגרמה לו הוצאה בהיבט זה לצורך קבלת הזכויות הנוספות, ועל כן אין מקום לקזז סכום תיאורטי שלא הוציא, ובכך להביא למצב של שווי גבוה יותר של זכויות שיישארו בידו מאשר אלו שעליהן ישלם לשכניו, דבר שיצור חוסר איזון.

לענין קיזוז סכומי היטל ההשבחה ששולמו בפועל ר' תיק (מפקחת על המקרקעין רחובות) 3/250/2017 **לוי נ' ענתבי** (נבו 30.11.2020); ת"א 21924-07-16 (שלום תל אביב) **בנסון נ' גרינבאום** (נבו 8.4.2018).

109. בענייננו, באשר לטענת הנתבעים בנוגע לאפשרות של אי עמידה בתנאי הסעיף – הרי שבשלב זה נראה שכבר חלפו 4 שנים מאז הסתיימה הבניה, כדרישת סעיף 19(ג)(2) האמור, והנתבעים לא טענו, וממילא לא הוכיחו, שמכרו את דירתם או שאינם עומדים בתנאי הפטור באופן שיאלצו לשלם את היטל ההשבחה.

110. העובדה ששמאי מכריע קבע במקרה דנן את גובה דמי ההשבחה בגין ההרחבות, אין רלוונטיות לענין זה שכן שמאותו מתייחסת למקרה שבו לא היה ניתן פטור, אולם משעה שעולה שניתן לנתבעים פטור מהיטל השבחה, הרי שאין מקום לקזז משווי הזכויות שקיבלו היטל השבחה תיאורטי שלא שולם.

התחשבות בסכומים שהוציאו הנתבעים לצורך קידום התב"ע

111. השמאית מטעמי בחוות דעתה מצאה מקום לקזז משווי זכויות הנתבעים סכומים כדלקמן:

א. הוצאות עלויות התכנון בסך של 152,000 ₪ על פי הצהרת אדריכל ספקטור, בהנחה ששולמו שווה בשווה על ידי בעלי תתי חלקות 1,8,9 ו-10 (הנתבעים). ר' עמוד 24 פסקה 7.6 לחוות הדעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. בנוגע להיטל השבחה – אמנם בסעיף 7.7. לחוות הדעת מצאה השמאית לנכון שלא להביא בחשבון את הפטור שניתן לנתבעים, אך גם לא ביצעה חלופה על פי תשלומים ששולמו בפועל, אלא על פי שווי תיאורטי, שכן תשלומים כאמור לא הוצגו בפניה. אולם בהמשך כאמור, בהתאם להחלטתי מיום 30.12.2021, אשר תאמה גם את מענה השמאית לשאלות ההבהרה מטעם התובעים בנוגע לכך שמדובר בסוגיה משפטית, ניתנה על ידי השמאית בהמשך גם חלופה המתייחסת לכך שהנתבעים קיבלו בפועל פטור מהיטל השבחה.

112. איני מקבלת את טענת התובעים שאין מקום לקזז את עלויות קידום התוכנית. עלויות כאמור הן עלויות ישירות שנגרמו לנתבעים לצורך קבלת זכויות הבניה, ועל כן, כפי שנכתב לעיל לעניין היטל השבחה, הנתבעים זכאים שעלויות שהוציאו בפועל כדי לקבל את הזכויות האמורות יופחתו משווי זכויות הבניה. תוצאה אחרת תביא לחוסר איזון, שכן תביא לכך שהתובעים ייהנו מתשלומי איזון על פי שווי זכויות גבוה, מבלי שהשתתפו בעלויות שהוצאו לצורך השגת אותן זכויות. לעניין זה ר' גם פסק דינו של חברי כב' המפקח אורי שלומאי בתיק (מפקח על המקרקעין חולון) **מיקה עידית נ' יקוטי אברהם** (נבו 13.4.2023) בפסקה 37.

113. חוות הדעת של השמאית מטעמי נתנה לפני סיום הליך ההוכחות. במהלך הליך ההוכחות נחקרו עדי הנתבעים על טענותיהם בדבר ההוצאות שהוציאו בפועל לצורך קידום התוכנית.

114. אדריכל ספקטור, אשר הצהיר מטעם הנתבעים בן חמו קיטנר ועמר, פירט בתצהירו שהנתבעים נשאו בעלויות התכנון שהיו מורכבות מ-100,000 ₪ בתוספת מע"מ הוצאות עריכת התב"ע, וכן 30,000 ₪ בתוספת מע"מ בשל מדידות וצילומים. לפיכך בסה"כ לטענת הנתבעים נשאו בסך של כ-152,100 ₪ כולל מע"מ לצורך קידום התב"ע (סעיף 2 לתצהיר אדריכל ספקטור). הסכומים האמורים נכתבו בתצהיר ספקטור באופן כללי וללא כל אסמכתאות. הנתבעים מצדם הסתמכו בטענותיהם לעניין עלויות אלו על תצהירו של אדריכל ספקטור, ועל מכתב כללי שנתן להם בעניין זמן רב לאחר מכן, הנושא תאריך 8.5.2017 (ר' נספח 2 לתצהיר בן חמו) תוך שצרפו אסמכתאות חלקיות ביותר המתייחסות לסכומים נמוכים בהרבה. אציין שהנתבעים מתייחסים בתצהיריהם למכתב האמור כ"הסכם שכ"ט" אולם לא מדובר בהסכם כזה, אלא במכתב כללי שניתן על ידי האדריכל כ-5 שנים לאחר אישור התב"ע, וממילא לאחר שהסתיימו כל התשלומים הנדרשים.

115. אדריכל ספקטור נחקר על תצהירו בעניין זה, וטען שמדובר בהערכת עלויות על בסיס ניסיונו אף שהכספים הועברו דרכו, אולם הוא לא שמר את המסמכים (פרוטוקול הדיון מיום 3.1.2022 עמוד 12 שורות 26-42).

116. מהאסמכתאות שצורפו על ידי הנתבעים לעניין הוצאות **קידום התב"ע** (להבדיל מהוצאות שהוציאו למימוש הבניה), עולה שהיו בידיהם אסמכתאות להוצאות כדלקמן:

א. חשבונית מיום 8.12.2010 לעניין תשלום סך של 4,640 ₪ על ידי קיטנר לספקטור (נספח 2 לתצהיר בן חמו)

ב. חשבונית מיום 23.4.2012 לעניין תשלום סך של 16,588 ₪ על ידי קיטנר לספקטור (נספח 2 לתצהיר בן חמו)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. שיק ע"ס 5,000 ₪ מיום 2.12.2009 חתום על ידי בן חמו ללא נמען, שיק על סך 8,000 ₪ מיום 2.11.2009 חתום על ידי עמר ללא נמען, אישור בכתב יד של ספקטור לקבלת 3,000 ₪ מבן חמו (נספח 2 לתצהיר בן חמו).

האסמכתאות שצורפו לתצהיר דהן מתייחסות כולן, למעט המכתב הכללי של אדרי' ספקטור, להוצאות שהוצאו לאחר אישור התב"ע לצורך הוצאת היתר בניה (ר' גם חקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 3.1.2022 עמוד 21 שורות 50-27 עמוד 22 שורות 19-1).

117. דהן טען בחקירתו שלא ביקש אסמכתאות למעט אותו מכתב כללי ואף חושב שלא קיבל חשבוניות מאדרי' ספקטור (פרוטוקול הדיון מיום 3.1.2022 עמוד 17 שורות 41-50), גם בן חמו טען בחקירתו שאינו זוכר במדויק את הסכום ששילם, שלא ביקש חשבוניות מספקטור, לו שולמו כל הסכומים, ואין לו אסמכתאות נוספות לעניין הסכומים ששילם (עמוד 24 שורות 6-38). גם באשר לסכום הכולל ולחלוקתו לא קיימת קוהרנטיות בטענות הנתבעים. בן חמו טען שהסכום חולק בן 4 הנתבעים (ר' פרוטוקול הדיון מיום 3.1.2022 עמוד 17 שורות 37-38), בעוד ליאור קיטנר בחקירתו הנגדית (מטעם הנתבעים קיטנר) טען שאותו סכום של כ-150,000 ₪ חולק ל-3 (פרוטוקול הדיון מיום 19.1.2022 עמוד 3 שורות 36-39). דהן מצדו טען בתצהירו שמדובר בסכום של 130,000 ₪ (על פי אותו מכתב כללי של אדרי' ספקטור) שחולק ל-4 (סעיף 45א) לתצהיר דהן).

118. באשר לטענת הנתבעים לנזק ראייתי שנגרם על ידי התובעים בשל מועד הגשת התביעה, הרי שכעולה מהאמור לעיל, מועד אישור התב"ע אינו רלוונטי לתביעה מסוג זה, אלא מועד ההחלטה לביצוע ההרחבה. לתובעים לא היתה כל גישה להיקף התשלומים הנדרש לצורך קידום התב"ע, שכן כל המידע בעניין היה בידי הנתבעים. על הנתבעים, אשר בחרו לקדם את התב"ע ללא שיתוף התובעים, האחריות לשמור את האסמכתאות הרלוונטיות ככל שהיה בכוונתם לדרוש בעתיד השתתפות בתשלומים כאמור. יתר על כן, בנוגע לבניית המעלית, שבוצעה בשנת 2010, עולה שבידי הנתבעים אסמכתאות רבות שהוציאו בין השנים 2009 – 2011 (נספח 29 לתצהיר בן חמו). לפיכך תמוה שדווקא לגבי הוצאות התכנון לא נשמרו אסמכתאות לגבי סכומים משמעותיים הנטענים על ידם.

119. נוסף על האמור, בהסכם שחתם דהן עם ירקוני בשנת 2016, נספח 7 לתצהיר דהן, עולה כי דהן עצמו ציין בהסכם (ב"והואיל" הרביעי) שעלויות הליכי התב"ע שממונו על יד בן חמו קיטנר עמאר ודהן מסתכמים בעלות של 100,000 ₪. כך צוין גם בהסכמים עם יתר הנתבעים (ר' נספח 8 לתצהיר בן חמו). הסכום האמור גם צוין במכתב מיום 31.1.2017 ששלח בא כוחו של דהן לבא כוחו של שמאי (ר' נספח 9 לתצהיר דהן פסקה 9). מכאן שהנתבעים עצמם חזרו מספר פעמים, בסמוך לפני הגשת התביעה, על כך שההוצאות שהוציאו לקידום התב"ע הם 100,000 ₪, ואף כללו סכום זה בהסכמים שחתמו עם בעלי דירות אחרים לעניין הסכמותיהם להרחבות שביצעו. מכאן שהבסיס לסכום שנטען על ידי הנתבעים ככזה שהוצא על ידם לצורך קידום התב"ע רעוע ביותר.

120. אף שבידי הנתבעים אסמכתאות לתשלום בפועל של סך של 37,228 ₪ בלבד, אני סבורה שבמקרה דנן, יש להתייחס לתשלום ששילמו הנתבעים לצורך קידום התב"ע על כסך של 100,000 ₪, בחלוקה ל-4 חלקים, דהיינו שכל אחד מהנתבעים שילם רבע מהסכום, כפי שאפרט להלן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על פי סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לקבוע תנאים לביצוע הרחבה, ובכלל זאת תשלומי איזון, היא סמכות הכוללת שיקול דעת רחב באשר לאופן בו יש לפצות את בעל הדירה שנפגע כתוצאה מהחלטת הרחבה. סמכות זו עומדת בהלימה גם להוראת סעיף 75(א) לחוק המקרקעין, לעניין סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, אם היה משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית צדק. סמכות זאת נובעת בין היתר ממערכת היחסים המיוחדת שבין צדדים להליכים המתנהלים לפני המפקח על רישום מקרקעין, שהם לרוב בעלי דירות שקיימת ביניהם מערכת יחסים ארוכת שנים, שיש לה היבטים נוספים על אלו הנדרשים במסגרת הליך מסוים, כאשר להכרעה בהליך יכולה להיות השפעה על המשך אותה מערכת יחסים. בענייננו, אני סבורה שהנסיבות המיוחדות נשוא ההליך דגן מצדיקות קביעת סכום גבוה מזה שנתמך באסמכתאות הרלוונטיות מטעם הנתבעים, גם אם נמוך מזה שנדרש על ידם בפועל, כפי שאנמק להלן.

ראשית, לפחות 3 מהנתבעים (עמר בן חמו ודהן) טענו כי הוצאות האמורות חולקו ל-4 תשלומים שווים בין כלל הנתבעים, והתובעים לא כפרו בכך. אולם האסמכתאות מתייחסות לתשלומים שבוצעו בתקופות שונות על ידי אחד או שניים מהנתבעים, ואין כלל אסמכתא לעניין תשלום כלשהו על ידי דהן. לפיכך ניתן להניח שאכן בוצעו תשלומים נוספים שלא נשמרו לגביהם אסמכתאות. ככל שמתייחסים לסכומים ששילמו קיטנר לבדם, ואשר לגביהם יש אסמכתאות, ומכפילים אותם ב-4 מגיעים לסך הקרוב ל-90,000 ₪ (כאשר יתכן שגם קיטנר שילמו סכומים נוספים אך לא שמרו את האסמכתאות בנוגע לכך).

שנית, כאמור, בהסכמים שנחתמו עם בעלי דירות אחרים נכתב שהנתבעים הוציאו 100,000 ₪ לקידום התב"ע, וסביר שהסכמים אלו נערכו לאחר מו"מ בין הצדדים להם, כאשר האינטרס של בעלי הדירות האחרים שהיו צד להם דומה לאינטרס התובעים, והם הסכימו לציון הסכום האמור כסכום ששולם על ידי 4 הנתבעים לקידום התב"ע. אף התובעים שמאי אינם כופרים בסיכומיהם בכך ששולם סך של כ-100,000 ₪ לקידום התב"ע, אך חולקים על הסכום הגבוה יותר שנדרש על ידי הנתבעים.

שלישית, אין מחלוקת שהתב"ע אכן קודמה על ידי הנתבעים בלבד, ושהתובעים קיבלו במסגרתה זכויות (גם אם מופחתות). אמנם הנתבעים לא שיתפו את התובעים בהליכי קידום התב"ע, אבל בנסיבות העניין, כאשר הם נהנים ממנה בפועל, ודורשים תשלומי איזון בגין הזכויות שנתנו במסגרתה, היה עליהם לכל הפחות להניח תשתית עובדתית לעלויות סבירות הנדרשות לקידום תב"ע כאמור, אולם הם לא עשו זאת. טענתם של התובעים בוף ובערש שניתן לקזז לנתבעים רק הוצאות על פי קבלות שהמציאו הנתבעים, תביא למסקנה בלתי צודקת, על פיה דהן, שאין בידם קבלות כאמור, לא יהיו זכאים לכל הפחתה שהיא בגין קידום התב"ע, אף שאין מחלוקת שהשתתפו בקידומה. לאור האפשרות הקרובה לודאי שאכן עלויות קידום התב"ע היו גבוהות יותר מהאסמכתאות שנשמרו, כעולה ממשך הזמן שחלף מאז שולמו התשלומים ויתר הנסיבות שפורטו לעיל, הכף נוטה לכך שיש להקל על הנתבעים באשר להיקף ומשקל הראיות שבידם.

שטח החצר

121. מחוות דעתה של השמאית מטעמי (עמוד 10 סעיף 4.1) עולה ששטח החצר בו נעשה שימוש על ידי דהן הוא 175.33 מ"ר, אולם משמאות הצדדים עולה כי מדובר בשטח של 150 מ"ר (כאשר השטח הרלוונטי הוא שטח חצר שלא שימש להרחבת דירת דהן ונותר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פנוי). מכיוון שאני סבורה שלא היה מקום לקחת בחשבון את שטח החצר לצורך התחשיב, אין מוצאת צורך להכריע מהו השטח הנכון.

השמאית מטעמי התייחסה בחוות דעתה, לבקשת דהן, ל-2 חלופות בעניין זה. האחת מתייחסת לשווי זכויות דהן ככאלו שכוללות את שטח החצר, והאחרת ללא שטח החצר. מתשובות השמאית בסעיף 7 למסמך מיום 14.12.2021 עולה ששטח החצר נלקח על ידה לצורך ביצע החשוב משום שסברה שהיא הוצמדה לדירת דהן. אולם בעניין זה קיימת טעות עובדתית בבסיס החישוב, שכן לא הוכח עובדתית שמתקיימות הנסיבות להצמדה קניינית של החצר לדירת דהן, ואין מחלוקת שמבחינה קניינית גם לא רשומה הצמדה קניינית כאמור. כמו כן קיימת טעות משפטית, שכן הצמדת שטח החצר, גם אם היתה מבוצעת, אינה הרחבת דירה המזכה בתשלומי איזון, אלא רכישת שטח משותף, שהתמורה בגינו אמורה להיות בהתאם להסכמות שבין בעלי הדירות.

122. כאמור, על פי סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, הצמדת רכוש משותף לאחת הדירות דורשת הסכמה של 100% מבעלי הדירות. סעיף 71 מאפשר הצמדה ברוב של 75% מהדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, אך זאת לצורך הרחבת דירה בלבד. לפיכך, כדי שדהן יהיו זכאים להצמיד לדירתם את שטח החצר, עליהם לקבל הסכמה של כל בעלי הדירות. לא קיימת הסכמה כאמור, שכן מהאמור לעיל עולה שלכל הפחות התובעים בערוש לא נתנו את הסכמתם להצמדת החצר, ודהן לא הוכיחו שיתר בעלי הדירות, שאינם צד להליך, הסכימו להצמדת שטח החצר לדירתם (למעט הטענה בנוגע לשתי דירות אחרות, של ירקוני וכהן, שחתמו עם דהן על הסכם). די בכך כדי לקבוע ששטח החצר אינו מוצמד לדירת דהן.

יתר על כן, הזכות לתבוע תשלומי איזון קיימת רק במקרה של הרחבת דירה, שאז ניתן לכפות את חלוקת הזכויות על פי החלטת רוב בעלי דירות, ועל כן נוצר מנגנון פיצוי לבעלי הדירות האחרים. לעומת זאת, הצמדת חצר אינה דורשת מנגנון כאמור, שכן לא ניתן לכפות על מי מבעלי הדירות להעביר זכויותיו בחצר. דהן עצמם טענו שאין מקום לכלול את שווי החצר במסגרת תשלומי האיזון. בהקשר זה יש להבהיר שדהן אינם רשאים לאחוז בחבל משני קצותיו – מכיוון שנמצא שלא כל בעלי הדירות הסכימו להצמדת החצר לדירת דהן, ומכיוון שלא ניתן לחייבם לעשות זאת, הרי שטענת דהן שאין מקום לחייבם בתשלומי איזון בגין החצר, המסתמכת על היעדר תחולה להסדר החקיקתי בנוגע להרחבת דירה, אינה יכולה לדור בכפיפה אחת עם טענתם לזכויות בלעדיות בחצר. עם זאת, בכל הנוגע להליך זה, מכיוון שהסעד שנתבע בנוגע לחצר הוא תשלומי איזון, הרי שיש לדחות את התביעות בעניין זה.

123. השאלה מה מעמדם של דהן בשטח החצר והאם מי מהתובעים זכאי לדרוש את הפסקת החזקה הייחודית שלהם בחצר לא נדונה בהליך זה, ועל כן איני מוצאת מקום להכריע בכך.

124. לא נעלם מעיני שלמרות טענת בערוש שאינם מסכימים להצמדת החצר לדהן, הם כללו את הסכומים בגין שווי החצר בתביעתם שהיא גם תביעת בוף, ובחוות הדעת שהוגשה מטעמם. סכומים בגין החצר נכללו גם בתביעת התובעים שמאי ובחוות הדעת מטעמם. אולם בתביעות האמורות עילת התביעה היא תשלומי איזון, תשלומים שכאמור אינם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רלוונטיים לנושא החצר. לפיכך ובהיעדר עילת תביעה רלוונטית, אין מקום לפסוק תשלומים בגין החצר.

125. מכאן, שלצורך בחינת דמי האיזון שעל דהן לשלם, אין מקום לקחת בחשבון את שווי החצר.

עלויות תיקון הגג, החלפת תשתית הביוב, ועלויות נוספות שנגרמו לתובעים לצורך מימוש הבניה

126. הנתבעים ביקשו מהשמאית מטעמי לכלול בחוות הדעת חלופה על פיה יופחתו הוצאות שלטענתם הוציאו לצורך תיקון גג הבית המשותף, אשר תוקן כחלק מעבודות בניית ההרחבות על גבי הגג, והקמת גג משותף חדש על ידי הנתבעים על גבי ההרחבות. כן ביקשו לכלול חלופה המתייחסת לצורך בהחלפת תשתית הביוב. השמאית מטעמי אמנם נתנה במסגרת המענה לשאלות ההבהרה מיום 25.1.2022 התייחסות לחלופות כאמור, אולם ציינה בכל הנוגע לתיקון הגג, שעלויות הבניה שהובאו בחשבון כבר מגלמות עלויות יתר בגין בנייה על הקיים, ולכן סברה שאין מקום להפחית סכום כאמור. כן ציינה בנוגע לעלות החלפת תשתית הביוב שעלויות הבניה שהובאו בחשבון מגלמות את העובדה שמדובר בבניין קיים ונדרשות התאמות מיוחדות שלא קיימות בבניין חדש, ועל כן להערכתה עלויות אלו כבר מגולמות בתחשיב ואין לחשבן בנפרד.

127. בעניין זה אני מקבלת את עמדת השמאית מטעמי, שכן מדובר בעמדה שמאית, באשר לכך שעלויות מסוג זה כבר נכללות במסגרת החישוב שביצעה (כפי שעולה בפסקה 7.12 בעמוד 26 לחוות דעתה). יובהר בהקשר זה, שבהתאם לפסיקה דלעיל, עלויות שיש מקום לקזזן במסגרת תחשיב דמי איזון, הן עלויות ישירות שהוצאו לצורך קבלת זכויות הבניה. הוצאות לצורך תיקון הגג והחלפת תשתית הביוב לא הוצאו לצורך **קבלת זכויות הבניה**, אלא לצורך **מימוש הבניה בפועל**. בהקשר זה, כעולה מחוות דעתה של השמאית מטעמי, מדובר בחלק **מעלויות הבניה**, אשר נבחנו על ידה על פי בנייה על קיים, ואף זאת ביתר, ועל כן מגלמות בתוכן כל סכום שנדרש להוציאו לצורך בניה על הקיים.

לאור האמור, מתייתר גם הצורך לדון בקיזוז עלויות נוספות שהוטלו על הנתבעים לצורך קבלת היתרי הבניה לביצוע ההרחבות, בכללם אגרות והיטלים הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה (למעט היטל השבחה המוטל בשל **תוספת זכויות הבניה**, לגביו הורחב לעיל).

128. טענות הנתבעים הן לעניין קיזוז עלויות שהוציאו לצורך ביצוע הבניה ובכללן תיקון הגג המשותף ובניית גג חדש והן לעניין החלפת תשתיות הביוב נדחות גם אם ההתייחסות אליהן תהיה כעילת תביעה עצמאית במסגרת התביעה שכנגד.

129. ראשית, כפי שנאמר לעיל, עלויות הבניה, ובכללן עניין זה, נלקחו בחשבון לצורך שווי הזכויות שקיבלו הנתבעים, ועל כן אין מקום להתייחס אליהן פעמיים, באופן שיקוזז כפל עלות.

130. שנית, גם במקרה של תביעה להחזר בגין תיקון הגג והחלפת תשתית הביוב כעילה עצמאית, ללא קשר לתשלומי האיזון, הנתבעים לא הוכיחו זכאות להשבת הוצאות בשל עבודות אלו. כפי שנקבע בפסק הדין ברע"א 4984/17 **שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא** (נבו, 14.12.17), ככלל, ביצוע תיקונים ברכוש המשותף אמור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להיעשות על ידי נציגות הבית המשותף. על בעל דירה המבקש החזר בגין הוצאות שהוציא לצורך ביצוע תיקונים ברכוש המשותף לעמוד בתנאים מצטברים מחמירים ובכללם להוכיח כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף; כי הדייר פנה לנציגות בדרישה לתיקון וזו סירבה לתקנו; כי העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי; כי הוכחה נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר לעשות שימוש בדירתו; כי הליקוי תוקן על ידי הדייר בצורה נאותה; כי הוכחה עלות התיקון.

במקרה דנן, הנתבעים לא טענו, וממילא לא הוכיחו את קיומם של מרבית התנאים האמורים, ובכללם דחיפות התיקון ופניה לנציגות וסירובה לבצעו. לפיכך, גם אם הייתה עומדת התביעה שכנגד כתביעה בפני עצמה, אף ללא קשר לתביעת תשלומי האיזון, היה מקום לדחות את טענות הנתבעים לעניין ההוצאות שהוציאו.

131. מבלי לגרוע מהאמור אוסיף, שבנסיבות העניין, לטענת הנתבעים שעל התובעים להשתתף בכל ההוצאות שהוציאו שכן התובעים נהנים מפירות הוצאות אלו, יש צדדים נוספים. הנתבעים פעלו על דעת עצמם לקדם את התביעה, מבלי שפנו קודם לכן לקבל את הסכמתם של הנתבעים לקידומה (גם אם חלקם היו מודעים בשלבים מאוחרים לקידומה). התביעה נותנת באופן מובהק זכויות בניה נרחבות לדירות הנתבעים ביחס לאלו של דירות התובעים. הפניה לתובעים לקבלת הסכמותיהם לזכויות הבניה הנרחבות שאושרו במסגרת התביעה, נעשתה רק בשלב מאוחר יותר, כאשר הנתבעים נאלצו לקבל את הסכמת הרוב הדרוש לצורך קבלת היתר בניה להרחבת דירותיהם, אף זאת תוך שהחלו בבניה בפועל טרם קבלת הסכמות כאמור. מכאן שלאורך תקופה ארוכה, ההתנהלות, שבמקרה הטוב, לא חשפה את ההיבטים הכרוכים בקידום התוכנית וקידום הבניה עצמה, ואף ייתכן שהסתירה היבטים אלו באופן מכוון, כדי להפחית הפרעות לקידומה, הייתה נוחה לנתבעים. מכאן שאין לנתבעים אלא להלין על עצמם על כך שבשלב מאוחר זה התובעים אינם מסכימים להשתתף בעלויות האמורות.

אי התחשבות בעלויות הקמת המעלית

132. על פי העולה מראיות הנתבעים עצמם, הנתבעים קיטנר בן חמו ועמאר קידמו קבלת היתר בניה להקמת מעלית בבית המשותף אשר ניתן ביום 14.6.2010. עלות הקמת המעלית מומנה על ידי הנתבעים האמורים, שהם בעלי דירות הגג. התובעים והנתבעים שכנגד סירבו להשתתף בהוצאות תכנון והקמת המעלית (ר' התייחסות לכך בחוות דעתו של השמאי יניב גוב ארי מטעם הנתבעים בן חמו קיטנר ועמר, בעמוד 10).

133. כעולה מהאמור, הקמת המעלית לא נעשתה כחלק מההרחבה, אלא נעשתה עוד לפני שאושרה התביעה שהוסיפה את זכויות הבניה לצורך ביצוע ההרחבות וממילא לפני מועד ביצוע ההרחבות. משכך, אין כל קשר בין הקמת המעלית לבין ההרחבות שביצעו הנתבעים, והיא אינה מהווה הוצאה ישירה לצורך ביצוע ההרחבות. לפיכך אני דוחה את טענת הנתבעים שיש להפחית את הוצאות הקמת המעלית מהערכת השווי לצורך חישוב תשלומי האיזון (ר' גם תשובות 15, 18 ו-19 במסמך השמאית מטעמי מיום 14.12.2021).

134. יתר על כן, אין מקום לחייב את התובעים בהשתתפות בעלות התקנת המעלית אף ללא קשר לנושא תשלומי האיזון. סעיף 159 לחוק המקרקעין קובע תנאים לעניין התקנת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מעלית בבית משותף קיים. על פי סעיף 159(ב)(1), בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית הם שיישאו בהוצאות התקנתה. הנתבעים לא טענו, וממילא לא הוכיחו, שהנתבעים נמנו על בעלי הדירות שהחליטו על התקנת המעלית. כל שהוכיחו הוא שהנתבעים קיטנר בן חמו ועמר קידמו במוסדות התכנון את נושא הקמת המעלית בשנת 2010, ושהנתבעים חתמו על הבקשה להיתר בניה בעניין זה. אין בכך כדי להראות שהיו שותפים להחלטה על הקמתה. להיפך, מהמסמכים שצירפו הנתבעים עולה שהם (עם בעל דירה נוסף) פעלו על דעת עצמם להתקנת המעלית, תוך שהתנו את השימוש של בעלי דירות אחרים במעלית בהשתתפות בחלקם היחסי (ר' נספח 28 לתצהיר בן חמו לעניין ההסכם שנחתם עם ספק המעלית עליו חתומים רק הנתבעים בעלי דירות הגג, ובעל דירה נוסף, וכן ההסכם שנחתם עם בערוש, נספח 14 לתצהיר בן חמו, בו נכתב שבערוש ישלמו את חלקם היחסי בהוצאות התקנת המעלית וישתתפו בתחזוקתה רק אם ירצו להשתמש במעלית). הנתבעים לא טענו וממילא לא הוכיחו שמאז התקנת המעלית בשנת 2010 ועד למועד הגשת התביעה דרשו ממי מהנתבעים להשתתף בתשלום בגין התקנתה, דבר המעיד אף הוא על פרשנות הנתבעים עצמם לכך שלא קיים בסיס לחיוב הנתבעים העלויות אלו. הטענה הכללית של הנתבעים כי "מי מטעמם של התובעים והנתבעים שכנגד משתמשים במעלית" (סעיף 63 לתצהיר בן חמו) אשר לא הוכחה, אינה מספקת כדי לחייב את התובעים בתשלום בגין התקנת המעלית.

אי התחשבות בבניה בלתי חוקית בדירת התובעים שמאי

135. על פי סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, תשלומי האיזון נועדו לאזן בין מי שמרחיב את דירתו מעבר לשיעור חלקו ברכוש המשותף, לבין מי שאינו יכול להרחיב את דירתו או שיכול להרחיב פחות מחלקו היחסי ברכוש המשותף. "הרחבה" לצורך סעיף 71ב מוגדרת בסעיף 71א כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תוכנית בת תוקף".

136. מכיוון שהטענה כלפי שמאי היא שמי שרכש את דירתם הרחיב אותה באופן בלתי חוקי מעבר לזכויות על פי התב"ע, הרי שגם אם הדבר נכון, לא מדובר בהרחבה שיש לקחת אותה בחשבון לצורך תשלומי איזון. כמו כן לנתבעים זכות לדרוש הריסה של אותה הרחבה, בשל היותה מנוגדת לחוק, ועל כן אין הגיון להפחית מתשלומי האיזון המגיעים בגין דירת התובעים שמאי, בשל ביצוע בניה שניתן לדרוש את הריסתה.

137. מעבר להיבט העקרוני האמור, הטענות לחריגות בניה שבוצעו על ידי רוכש דירת התובעים שמאי הן טענות להרחבה של מספר מטרים מעבר למה שאושר בתב"ע, ולתוספת של שטח מרפסת כשטח עיקרי (ר' סעיפים 44, 45 לתצהיר בן חמו, ונספח 19 לתצהירו), תוך שנטען שהוצא צו מנהלי להפסקת העבודה. מכאן שספק אם החריגות האמורות עדיין קיימות, וכן עולה שגם אם הן קיימות, הרי שמדובר בהיקף בניה נוספת קטן משמעותית ביחס לפער בין זכויות הבניה שקיבלו כל אחת מדירות הנתבעים לבין אלו שקיבלה דירת התובעים שמאי. במצב דברים זה, של בניה שאינה חוקית, ומצומצמת בהרבה מהבניה שבוצעה על ידי הנתבעים, לא ניתן לראות באותה בניה משום "הרחבה דומה" להרחבות שביצעו הנתבעים במובן סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין. בכל מקרה, גם הרחבה דומה, כאשר מתקיימת, רלוונטית לנושא ההסכמה לעצם בניית ביצוע הרחבת דירה על ידי בעל דירה אחר, אך אינה גורעת מזכותו של בעל דירה שהיקף ההרחבה בדירתו קטן מזה של בעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירה אחרת (אף כאשר ניתן לראותו כ"דומה" במובנים אחרים שנקבעו בפסיקה) לדרוש תשלומי איזון.

אי הפחתה של שטח היטל המדרגות

138. טענת הנתבעים לעניין הפחתת שטח היטל המדרגות מהתחשיב של השמאית מטעמי דינה דחייה. כפי שהבהירה השמאית מטעמי, שטח דירת מגורים לצורך חישוב השווי הוא שטח "פלדלת" הכולל את כל השטח בתחום הדירה, ועל כן אין לפחית את היטל המדרגות בקומה העליונה (ר' מסמך השמאית מיום 14.12.2021 פסקה 5). השמאית ציינה שגם בחוות של השמאי גוב ארי מטעם הנתבעים בן חמו קיטנר ועמר, לא הופחת שטח היטל המדרגות במפלס העליון.

מכאן שמדובר בשאלה הנוגעת לשיטת חישוב שמאית שאינה שאלה משפטית, ועל כן אין מקום להתערב בקביעת השמאית המומחית בעניין זה, שהוא עניין שהמומחיות.

המועד הקובע לצורך חישוב תשלומי האיזון

139. בחוות דעתה של השמאית מטעמי נתנו חלופות לבחינת דמי האיזון על פי 3 מועדים קובעים אפשריים. האחד, שנת 2012, מועד אישור התב"ע, השני שנת 2016, מועד הוצאת היתרי הבניה, והשלישי שנת 2021, מועד עריכת חוות הדעת.

140. על פי סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, תשלומי האיזון צריכים להיות משולמים במועד החלטת ההרחבה. כפי שנכתב בהחלטת כב' המפקחת (דאז) ענתבי שרון מיום 29.3.2020 בתיק בקשה 51/19, בפסקאות 8, 9, על פי הוראת סעיף 71ב(א) דרך המלך היא לקבל הסכמה של בעלי הדירות לפני ביצוע ההרחבה. אולם בפועל עולה שלעיתים בעלי דירות מרחיבים קודם את דירתם, ורק לאחר מכן מקבלים את ההסכמות הנדרשות. במצבים כאמור, נקבע בהחלטה, מבלי לקבוע מסמרות בעניין, לשם בחינת התגבשות עילת התביעה, וכדי שלא יצא חוטא נשכר, המועד לצורך התגבשות העילה לצורך תביעת תשלומי איזון יהיה מועד הבניה בפועל, אף שלצורך בחינת מועד הגשת התביעה, יש לבחון את המועד הקובע כמועד בו התקבלה ההסכמה האחרונה המגבשת קבלת רוב בעלי הדירות על פי דין.

141. עם זאת, חשוב לציין שככל שההרחבה בוצעה שלא כדין, דהיינו, שלא ניתן לקבל היתר לפי תכנית בת תוקף לצורך ביצוע ההרחבה כאמור, כהגדרת "הרחבה" בסעיף 71א לחוק המקרקעין, הרי שבניה כזו אינה מזכה בתשלומי איזון על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, וזכות בעלי הדירות האחרים לבקש הריסתה.

142. בענייננו, היתר הבניה לבנייה שביצעו כל הנתבעים ניתן בשנת 2016, ואף הבנייה בפועל בוצעה באותה שנה. כמו כן, כפי שעולה מהאמור לעיל, גם גיבוש הרוב הדרוש לצורך ביצוע ההרחבות היה בפועל בשנת 2016, עם קבלת הסכמת ירקוני (הגם שכאמור, לצורך בחינת המועד להגשת התביעה, יש מקום להתחשב במועד בו נודע על כך לתובעים). על כן, גם מועד גיבוש הרוב הדרוש לקבלת החלטה להרחבה, וגם מועד ביצוע ההרחבה בפועל, תואמים את החלופה המתייחסת לשנת 2016.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

143. טענת התובעים שהמועד הקובע הוא מתן חוות דעת השמאית מטעמי נדחית. המועד בו ממונה שמאי מטעם המפקח בעקבות תביעה של בעל דירה על פי סעיף 71ג(א) לחוק המקרקעין אינו רלוונטי למועד הקובע לגביו על אותו שמאי לחשב את תשלומי האיזון. מועד כאמור הוא מועד שרירותי התלוי במועד בו הוגשה התביעה ובהתנהלות ההליך המשפטי, ומנוגד להוראת סעיף 71ב(ד) הקובעת כי תשלומי האיזון ישולמו במועד קבלת החלטת ההרחבה, דהיינו, זה המועד שבו למעשה זכאי בעל הדירה המרחיבה לקבל את הזכויות לצורך ביצוע ההרחבה, ועל כן באותו מועד התגבשה חובתו לשלם ליתר בעלי הדירות את חלקם. על כן, ככלל, ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, שינויים בערך הקרקע לאחר מועד זה אינם אמורים להילקח בחשבון לצורך תשלומי האיזון שכן מדובר בנסיבות שאירעו לאחר התגבשות העילה לצורך הגשת התביעה. בכל מקרה, במקרה דנן, לא מצאתי שיש לקחת בחשבון שינויים כאמור, שכן עם הגשת התביעות לדמי איזון, בסמוך לאחר מועד קבלת ההיתר וביצוע הבניה, למעשה הביעו כל הנתבעים את הסכמתם לביצוע ההרחבות, והתביעות שהגישו מתייחסות אף הן למועד קבלת ההחלטה שהוא בשנת 2016 ולכל היותר בתחילת שנת 2017.

144. גם טענת הנתבעים על פיה המועד הקובע הוא בשנת 2012, מועד אישור התב"ע, נדחית, שכן אין לה כל תימוכין בחוק או בפסיקה (האסמכתאות שהובאו על ידי דהן בסיכומיהם בעניין עוסקות בעניין אחר ואינן רלוונטיות לתשלומי איזון בגין הרחבת דירה על פי חוק המקרקעין).

טענות נוספות בנוגע לחוות הדעת

145. טענת הנתבעים קיטנר בן חמו ועמר שהתב"ע קובעת זכויות קנייניות או שהיא משייכת את זכויות הבניה באופן פרטני שאינו מקנה זכות לתביעת תשלומי איזון, נדחית.

בפסיקה נקבע, שכברירת מחדל, זכויות בניה בבית משותף יחולקו בין בעלי הדירות בהתאם לחלקם ברכוש המשותף (ר' לדוגמא ע"א 6900/14 לויט נ' בנבנישתי (נבו) 28.9.2016). כן נקבע שאין בעובדה שזכויות בניה ניתנות לניצול על ידי הדירה בקומה העליונה בלבד, כדי להביא למסקנה שזכויות אלו שייכות לאותה דירה, זאת אף כאשר הגג צמוד קניינית לדירה העליונה [ר' ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, נד (3) 389, בעמ' 393 (2000), וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד לז(2) 497, 501-502 (1983)].

כמו כן נקבע, שאף אם תכנית מוסיפה זכויות בניה תוך קביעה שהאפשרות לניצולן היא על ידי הדירה העליונה בלבד, ככלל, אין בכך כדי להביא לפרשנות המקנה את אותן זכויות מבחינה קניינית לאותה דירה, ללא הוראות בדבר הקצאה קניינית מפורשת, שכן תכנית עוסקת בתכנון ולא בקניין (ר' ת"א (שלום הרצליה) 4784/11/16 רוז נ' ארנן (נבו) 25.12.2018 פסקה 36).

146. אין בטענת הנתבעים שהתובעים לא התנגדו לתב"ע כדי לשלול מהם את הזכות לתבוע תשלומי איזון. ראשית, לא נטען, וממילא גם לא הוכח, שהתובעים הביעו הסכמה מפורשת לקידום התב"ע. עצם ידיעת התובעים על קידום התב"ע בשלביו הראשונים מוטלת בספק. שנית, גם אם התובעים היו מסכימים לקידום התב"ע, לא ניתן להסיק מכך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהסכימו להקצאת מרבית זכויות הבניה שהתב"ע מקנה דווקא לנתבעים, בניגוד לברירת המחל של שנקבעה בפסיקה. יתר על כן, לאור המו"מ שהתנהל בינם לבין הנתבעים בעניין, מובן שלא היו מסכימים לכך ללא כל תמורה.

147. גם הטענה שאושר לתב"ע נספח בינוי מפורט, המסמן את ההרחבות לכל קומה ודירה בנפרד, אין בה כדי לסייע לנתבעים. כעולה מהפסיקה שפורטה לעיל, גם כאשר זכויות בניה שהוקצו במסגרת תב"ע ניתנו לניצול על ידי בעלי דירה מסוימת בלבד, אין בכך כדי להביא למסקנה שהתב"ע קובעת זכויות קנייניות, באופן שאותן זכויות שייכות קניינית לאותה דירה. למעלה מן הצורך אוסיף שספק אם נספח הבינוי האמור אכן בעל מעמד מחייב שכן כפי שצוין במענה השמאית מטעמי מיום 14.12.2021 בסעיף 21, נספח הבינוי הוא מנחה בלבד וההיתר שניתן בסופו של דבר אינו נגזרת שלו ואף שונה ממנו. בפועל, גם על פי תצהיר אדריכל ספקטור מטעם הנתבעים, זכויות הבניה שנוצלו על ידי הנתבעים קיטנר בן חמו ועמר על פי ההיתר מצומצמות מאלו שקבע נספח הבינוי, ועל כן גם השמאית מטעמי לקחה בחשבון לצורך תשלומי האיוון זכויות פחותות מאלו שבנספח הבינוי (ר' עמוד 20 לחוות דעתה של השמאית מטעמי, וכן עמוד 22 סעיף 7.3).

טענות הנתבעים דהן כלפי התובעים שמאי לעניין פגיעה בפרטיות

148. הנתבעים דהן טענו במסגרת תביעה שכנגד שהתובעים שמאי פגעו בפרטיותם בשל התחזות של השמאי פטל מטעם התובעים שמאי לעובד עירייה וכניסתו לדירת דהן כדי לצלם בה. לטענתם השמאי פטל נמלט מדירתם לאחר שנשאל לפשר מעשיו, והצביע על שמאי שעמד אותה עת בחדר המדרגות כמי ששלח אותו.

149. לטענתם, עקב כך הם זכאים לפיצוי על פי סעיף 29א(ב)(1) **לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981** (להלן – חוק הגנת הפרטיות), בסך של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק. לטענתם, האירוע פגע בנפש בנותיהן, שפתחו חרדות.

150. התובע שמאי לא התכחש לנסיבות המקרה, אלא טען שלא הוא שנכנס לדירה (הדבר מוסכם על הנתבעים דהן) ושהטענה נטענה באופן כללי ולא גובתה בראיות מתאימות כגון חוות דעת רפואית.

151. התובע שמאי לא העלה טענה לעניין הסמכות העניינית של ערכאה זו לדון בסעד מסוג זה, אך אני מוצאת מקום לציין שמלכתחילה אין סמכות עניינית לערכאה זו לדון בסעד כאמור (לעניין סמכויות המפקח על רישום מקרקעין ר' סעיף 72 לחוק המקרקעין). עם זאת, בנסיבות אלו, שבהן הסעד האמור נכלל בתביעה שכנגד של הנתבעים דהן, אשר הועברה מבית משפט השלום לערכאה זו יחד עם התביעה העיקרית של שמאי, בשל היעדר סמכות עניינית לבית משפט שלום לדון בסעדים העיקריים שהתבקשו בתביעות אלו, ובהיעדר טענות בעניין מטעם התובע שמאי, אני רואה מניעה לדון בסעד האמור לאור הוראת סעיף 79 **לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]**, **תשמ"ד – 1984**.

152. לגופו של עניין, טענות הנתבעים דהן בהקשר זה נתמכו בתצהיר דהן (ר' סעיפים 32-34 לתצהיר ונספח 8 שכולל 2 פרוטוקולים של דיון בבית משפט השלום בירושלים והחלטות לעניין הטרדה מאיימת שנתנו ביום 25.7.2016 וביום 31.7.2016 כנגד תובע שמאי והשמאי פטל מטעמו) ולא נסתרו בחקירתו הנגדית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

153. סעיף 29א(ב)(1) לחוק הגנת הפרטיות מאפשר פסיקת פיצוי בגין פגיעה בפרטיות ללא הוכחת נזק, ועל כן טענת התובעים שמאי להיעדר ראיות לעניין הנזק נדחת.

כניסה לדירה לצורך ביצוע צילומים, שלא בהסכמת בעל הדירה, ואף כניסה מטעם בעל הדירה כאשר הוא עצמו לא נכנס לדירה, הוכרה בפסיקה כפוגעת בפרטיות [ר' לדוגמה ת.א. (שלום ת"א) 45927-02-15 ויינברג נ' פיצ'חזזה (נבו 18.1.17) אשר ערעור ובר"ע שהוגשה בעקבותיו נדחו – ר' רע"א 7706/17 ויינברג נ' פיצ'חזזה (נבו 5.12.2017) וכן ת"ק (קריות) 5206-07-20 בראל נ' לוי (נבו 18.5.2021)].

154. בענייננו, מהנסיבות עולה שאלמלא התחזה השמאי פטל לעובד עירייה, לא הייתה מתאפשרת כניסתו לדירה, שאחרת לא היה מתחזה ולא היה "נמלט" כאשר נדרש לספק אסמכתה לזכותו להיכנס לדירה, ועל כן מדובר בכניסה ללא הסכמת דהן. בהתחשב בכך שלא נטען שהתמונות שצולמו פגעו באופן כלשהו בדהן, והפגיעה הנטענת היא בחרדות שנגרמו לבנותיהם של הזוג דהן בשל כניסה זו, אף שבני הזוג עצמם היו בבית, ואף שהביאו ל"המלטות" של השמאי פטל תוך זמן קצר, אני קובעת שעל שמאי לשלם לדהן פיצוי בסך של 5,000 ₪.

התחשיב הקובע לצורך ביצוע תשלומי האיזון

155. חוות דעתה של השמאית מטעמי כללה חלופות שונות, המתייחסות כל אחת רק לחלק מהעקרונות שפורטו לעיל, ולא קיימת חלופה אחת הכוללת את כולם. כמו כן, בכל הנוגע לסכומים ששימשו לאישור התב"ע, התייחסה התייחסה השמאית מטעמי לסכומים שנטענו על ידי הנתבעים, כאשר בדיעבד, ולאחר שמיעת הראיות, עולה שהיה מקום להתחשב בסכום נמוך יותר. מאידך, גם השמאיות שהוגשו מטעם הצדדים אינם כוללים תחשיב התואם את העקרונות האמורים. לפיכך, על השמאית מטעמי לבצע תחשיב נוסף, העומד בקביעות פסק הדין על-פיו:

- א. המועד הקובע הוא שנת 2016.
- ב. אין לקחת בחשבון את שטח החצר שבשימוש דהן.
- ג. יש לקחת בחשבון את סכומי היטל ההשבחה ששולמו בפועל על ידי הנתבעים, תוך התחשבות בפטור שניתן להם.
- ד. אין לקחת בחשבון את עלויות תיקון הגג, התקנת המעלית ויתר העלויות שנדרשו לצורך מימוש הבניה.
- ה. אין להפחית את שטח היטל המדרגות.
- ו. יש לקחת בחשבון את הוצאות קידום התב"ע בהתייחס לסך של 100,000 ₪ בלבד.

156. לאור האמור, אני קובעת כי על השמאית מטעמי להכין בתוך 30 יום מהיום, טבלה בהתאם לעקרונות האמורים, אשר תכלול, בנוסף על האמור לעיל, גם את הסכום הסופי שעל כל אחד מהנתבעים לשלם בפועל לכל אחד מהתובעים, בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/418/2018, 1/419/2018, 1/29/2019,
1/47/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

157. לאחר הכנת טבלה כאמור, ובכפוף לכך יהיו רשאים התובעים להגיש בתוך 14 יום בקשה לאישור פסיקתה התואמת, בכל הנוגע לתשלומי האיזון, את התחשיב הסופי כפי שיופיע בטבלה (ככל שלא יעלו טענות בנוגע לתחשיב בהיבטים טכניים). הנתבעים יהיו רשאים לתת תגובתם לפסיקתה המבוקשת בתוך 14 ימים נוספים.

158. במסגרת הבקשה לאישור פסיקתה ובמסגרת התגובה יהיו הצדדים רשאים לטעון לעניין המועדים לביצוע התשלומים, ובמסגרת הפסיקתה אתן הכרעה בעניין.

159. מהסכום שיחויבו הנתבעים דהן לשלם לתובעים שמאי יופחת סך של 5,000 ₪ בגין פגיעה בפרטיות.

160. כל הסכומים האמורים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה על ידי כל אחד מהתובעים ועד למועד התשלום בפועל.

161. באשר להוצאות ההליך, בהתחשב במורכבות ההליך ובתוצאותיו אני קובעת כדלקמן:

א. על הנתבעים דהן לשלם לתובעים שמאי סך של 15,000 ₪ כהוצאות ההליך, ולתובעים בוף ובערוש יחד, סך של 15,000 ₪ כהוצאות ההליך.

ב. על הנתבעים בן חמו עמר וקיטנר לשלם יחד ולחוד לתובעים שמאי סך של 18,000 ₪ כהוצאות ההליך, ולתובעים בוף ובערוש יחד סך של 18,000 ₪ כהוצאות ההליך.

ניתן היום, י' אלול תשפ"ג, 27 אוגוסט 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים